
Lección III

La creación del derecho y la ciencia jurídica en la época moderna (del nacimiento del estado al final del Antiguo Régimen, siglos XV-XVIII)

PID_00230265

Oriol Oleart

Índice

Introducción.....	5
1. Contexto geopolítico.....	7
1.1. La expansión europea: descubrimiento de América y redimensionamiento del mundo conocido	8
1.2. Imperios europeos, correlación de fuerzas, políticas internacionales de intereses	11
2. El estado moderno.....	12
2.1. El estado moderno: aparición en la Baja Edad Media-edad moderna. Concepto	12
2.2. Teorización, autores	18
2.3. Cambios estructurales	19
2.4. Transformación de los órganos centrales del estado: gobierno por consejos y administración	23
2.4.1. Gobierno por consejos	24
2.4.2. Instituciones de la monarquía, de los reinos	26
2.5. La teorización de la soberanía en el siglo XVI: Jean Bodin	28
2.6. Camino del absolutismo	30
3. La consolidación del poder regio, el derecho general y la prelación de fuentes.....	38
3.1. Poder regio, derecho del rey y derecho del reino	38
3.2. Derecho general territorial y órdenes de prelación de fuentes ...	39
3.2.1. Derecho general territorial	39
3.2.2. Órdenes de prelación de fuentes	47
3.3. Las compilaciones o recopilaciones de normas jurídicas	49
4. Los juristas y la construcción del estado.....	55
4.1. La generalización de las profesiones jurídicas	55
4.2. La especialización en los cargos y oficios de las instituciones públicas	55
4.3. La contribución de los juristas en la creación de la ciencia del derecho	56
4.4. Humanismo jurídico, las bases de una nueva concepción del derecho (siglos XV-XVIII)	58
4.4.1. <i>Mos gallicus</i>	59
Bibliografía.....	63

Introducción

En este bloque veremos cuál es el proceso que sigue el fortalecimiento de la monarquía, la entrada en escena y la consolidación de la nueva realidad que es el estado moderno, la evolución del derecho y la legislación, y de qué manera se recogen las leyes en algunos de los territorios europeos occidentales. Veremos también cuál es el papel de los juristas en la formación doctrinal y la teorización del estado, en la ciencia del derecho y en la teorización de la soberanía. Acabaremos con el paso de las monarquías hacia el absolutismo.

1. Contexto geopolítico

El marco temporal de este módulo abraza el periodo conocido como la **edad moderna**. Va desde finales de la Baja Edad Media, al acabar del siglo XV, hasta el inicio de la edad contemporánea, a finales del siglo XVIII. Los hechos históricos que nos sitúan cronológicamente son, por un lado, al inicio el descubrimiento de América en 1492 y, por el otro, al final el estallido de la Revolución Francesa, en 1789.

Edad moderna

Hay que tener en cuenta que hay autores de otras tradiciones que sitúan la fecha de inicio en 1453, con la caída de Constantinopla y el Imperio Romano de Oriente ante los turcos.

La situación de los territorios europeos occidentales en la edad moderna, de entrada, podríamos decir que fue una continuación del mundo medieval, si bien con novedades bastante relevantes (progresos técnicos y científicos, corrientes de pensamiento...). Así, junto con una herencia política y jurídica bajomedieval basada en el contexto feudal de las monarquías cristianas entonces existentes, había otros factores que vendrían a modificar a lo largo del periodo moderno las visiones, las relaciones y las correlaciones de fuerzas existentes en los diferentes territorios.

Nos interesa destacar que, a grandes rasgos, se evidenciará una diferencia de la óptica y el modo de hacer entre las maneras de proceder más propias de la Baja Edad Media y las derivadas de la nueva realidad de la época moderna. Entre las primeras estaría, por ejemplo, la sociedad estamental basada en el pacto, la tradición, el privilegio; también la legislación basada en la tradición y los compromisos del monarca, o la misma monarquía cristiana basada en la estructura de poder piramidal, de origen feudal. Entre los segundos estarían, por ejemplo, los nuevos estados fortalecidos –algunos convertidos en potencias internacionales–, y estarían también los derivados de una nueva concepción de la realidad donde se evidenciaría, por la misma dinámica de los hechos, que la herencia bajomedieval encorsetaría cada vez más, si no es que las limitara, a las nuevas monarquías y a sus necesidades para gestionar sus extensos territorios, situación que llevaría hacia un nuevo modelo de monarquía, absoluto, que acabaría prescindiendo de buena parte de toda esa herencia.

Esta diferencia de ópticas y de criterios, común a varios ámbitos, en la medida en que también reflejaba intereses políticos diferentes, afectaría y condicionaría de una manera definitiva las relaciones entre las monarquías y los miembros de los diversos estamentos de los diferentes territorios con personalidad jurídica diferenciada que las integraban.

Europa a comienzos s. XVI (con los Reyes Católicos).



Fuente: <https://platero4b1.files.wordpress.com/2013/02/mapa-europa-reyes-catolicos1.gif>

1.1. La expansión europea: descubrimiento de América y redimensionamiento del mundo conocido

No es ahora el momento de tratar en detalle los grandes cambios que, en general en Europa, se produjeron en este periodo. Basta recordar el descubrimiento del continente americano (1492) o la complejidad de la situación con, por ejemplo, las guerras de religión en Francia (1562-1598), la ruptura con la Iglesia católica de Enrique VIII de Inglaterra (rey de 1509 a 1547), la reforma protestante con Martín Lutero (1483-1546), el Concilio de Trento (1545-1563) y la Contrarreforma (segunda mitad del siglo XVI); la evolución hacia un sistema basado en el capital, favorecida por la ampliación de los mercados y los flujos de comercio que se establecieron, tanto en ámbito europeo como intercontinental con los territorios americanos, y también, a raíz de la conquista, colonización y evangelización de los nuevos territorios transoceánicos, toda la discusión en relación con el hecho de si los indígenas (en general, pero especialmente los americanos) tenían alma o no; por no hablar de los progresos técnicos y científicos o del papel de la imprenta, entre otras muchas cuestiones.

Herencia de Carlos V



Fuente: <http://www.heras-santos.net/Docencia/Diploma%20de%20Estudios%20Hispanicos/mapa%20Carlos%20V.jpg>

Imperio de Felipe II



Fuente: http://www.univ-montp3.fr/boeglin/cours/c_civi_docs/docs/mapamundi_imperio_felipeii.jpg

En cuanto a los cambios que más nos interesan, empiezan por la **concepción misma del mundo** y de sus nuevas dimensiones, a raíz del descubrimiento del continente americano.

Podríamos decir que el resto de cambios y evolución, si no son derivados de todo ello, sí se verían profundamente afectados por ellos e irían a remolque de este redimensionamiento del mundo hasta entonces conocido hacia una concepción de un mundo de una medida, de unas dimensiones, mucho mayores.

Las monarquías de los diferentes territorios europeos, como sabemos, se habían ido consolidando estructural y políticamente a lo largo del periodo precedente. En la época moderna tuvieron que seguir afianzándose, a la vez que tenían que afrontar nuevos retos. Y tuvieron que hacerlo superando la visión, digamos, más «local» o «regional» del mundo conocido en este nuevo mundo, que desde entonces ya no se movía a escala internacional, sino también intercontinental, y en el cual ya se divisaba cuáles serían las grandes potencias.

Lo hicieron abandonando esa visión más próxima, más inmediata (por comparación, se podría decir que «más limitada»), que se tenía en la Baja Edad Media; y fueron entrando progresivamente en una nueva perspectiva, bastante más amplia, mucho más global, geográfica y conceptualmente hablando, europea,

internacional y en parte intercontinental (con los territorios conquistados y dominados de las colonias), en la cual las diversas monarquías del viejo continente fueron ocupando y consolidando su lugar en la escena internacional.

1.2. Imperios europeos, correlación de fuerzas, políticas internacionales de intereses

La sociedad del momento, en el camino de la construcción de los imperios europeos, y la consolidación de las potencias, en un marco cada vez más amplio e internacional, con los conflictos de intereses consiguientes, también a escala internacional, empezaba a manifestar elementos relevantes de cara a la modificación de las correlaciones de fuerzas heredadas del mundo medieval.

Esta sociedad moderna, pues, como tal, seguía siendo estructuralmente estamental de base (por lo que respectaba a las posesiones, a los dominios, a las formas de explotación del campo, etc.), si bien la burguesía, y en concreto, la burguesía comercial, había ganado e iría ganando cada vez más peso, primero estrictamente económico, y, a partir de ahí, también político. Y lo haría a medida que el comercio, la producción industrial y la circulación de bienes fueran creciendo y ganando presencia en los mercados, lo que haría que los burgueses ganaran influencia ante los monarcas y sus círculos.

Podemos citar un caso único en el contexto medieval mediterráneo, propio del ámbito profesional mercantil, y al margen de las estructuras estatales, por la importancia que tuvo desde la Edad Media: la institución, avalada por privilegios reales, del Consulado de Mar y la normativa del *Libro de Consulado de Mar* en relación con el comercio marítimo y las instituciones anejas, como por ejemplo los seguros marítimos, la letra de cambio o las compañías mercantiles, que estaban en la base de un nuevo mercado de capitales.

La **propiedad de la tierra** seguía siendo un signo inequívoco de riqueza y, sobre todo, de poder, y la aristocracia, los nobles –y también las órdenes religiosas– continuaban siendo los dueños de las grandes propiedades; rodeaban a la monarquía y a la vez velaban por sus propios intereses. En este sentido, además de la situación económica, había otros elementos a tener en cuenta, como las largas tradiciones de alianzas con la monarquía de algunas familias, o situaciones de hecho, como veremos más adelante: bastantes miembros de familias aristocráticas, debidamente formados y preparados, entraron al servicio de las instituciones del estado para ocupar los cargos y oficios, y se especializaron profesionalmente en el campo de la administración institucional.

2. El estado moderno

2.1. El estado moderno: aparición en la Baja Edad Media-edad moderna. Concepto

Uno de los cambios más significativos en este periodo de transición de la Baja Edad Media a la edad moderna es la aparición del estado, la aparición y la consolidación del llamado **estado moderno** que, superando las limitaciones feudales, toma cuerpo alrededor de buena parte de las monarquías europeas.

¿Qué significa *estado moderno*? En relación con la delimitación del concepto que designa este fenómeno histórico y sus coordenadas de espacio y tiempo, conviene darse cuenta de la dificultad que puede haber para conocer, de entrada, el sentido del término *estado*, sobre todo porque no coincide con otros términos que se habían empleado o se empleaban hasta entonces para designar las estructuras de poder político en un determinado territorio. Centrándonos en la terminología, y dependiendo de las ópticas, el uso que se ha hecho históricamente del equivalente del término *estado* ha variado, según los territorios y las épocas, y se ha empleado terminología referida a la forma de organización política. Así, se ha podido documentar que se habían usado, por ejemplo, los términos *civitas* (ciudad), *status rei publicae* (república) o *regnum* (reino), entre otros.

En todas estas realidades designadas con términos diferentes, se encuentran elementos comunes como pueden ser: la **población**, el **territorio**, la **organización social** o la **organización política**. No ha de extrañar, porque algunos de estos elementos estaban presentes ya en los reinos medievales y reflejaban la existencia de diferentes formas de organización social regidas por monarquías cristianas (por ejemplo, los territorios medievales con personalidad jurídica diferenciada, en la península ibérica, organizados la mayoría como reinos, como por ejemplo Castilla, Aragón, el condado de Barcelona...). En este sentido, son elementos que desde entonces funcionaban o acabarían funcionando como elementos aglutinadores alrededor de la nueva realidad estatal que se estaba afianzando, y que acabarán siendo elementos definidores de las realidades nacionales, del concepto de nación, de estado nacional en el siglo XIX, si bien lo que era verdaderamente determinante no era tanto la existencia de estos elementos compartidos –que ya existían antes en relación con los reinos– como la estructura peculiar y concreta que formaban en cada caso.

Estado moderno

Una puntualización previa para evitar confusiones: un uso poco cuidadoso e impreciso de la terminología puede inducir a error. Debe evitarse confundir el concepto de **estado moderno** –propio del final de la Baja Edad Media y de la edad moderna– con el de **estado liberal de derecho**, **estado constitucional** o **estado nacional**, propio de la edad contemporánea, una vez desaparecido el Antiguo Régimen.

El concepto **estado** es un concepto complejo *per se* y, más, si le añadimos perspectiva histórica. A grandes rasgos, podríamos decir que el **estado** es una forma de organización política histórica nueva que se fue formando entre los siglos XIII y XX.

Una definición de trabajo para aproximarnos al concepto de **estado** podría ser entender que el **estado moderno** es la forma de organización política por excelencia de la edad moderna, una formación social histórica, organizada como una unidad política, que tiene unos rasgos estructurales característicos y que se va constituyendo, a partir de la sociedad europea occidental bajomedieval, alrededor de las monarquías de los diferentes territorios, de los siglos XIII al XV (en una fase de conformación y afianzamiento) en adelante (en una fase de consolidación en la época moderna, en los siglos XVI-XVIII), hasta el siglo XX.

Dado que, como acabamos de ver, el **estado moderno** es la forma de organización política por excelencia de la edad moderna, algunos autores consideran la expresión **estado «moderno»** redundante, por la época en que deviene protagonista. Por otro lado, hay autores que, al tratar el estado moderno, evitan hacer referencia a su momento de «aparición» o de «nacimiento», en la medida en que consideran que el estado es una formación social histórica de organización política fruto de un proceso de construcción, en transformación continua y progresiva, que enlaza de manera gradual y directa con las formas de organización política que lo han precedido, mientras que, por otra parte, hay quienes creen que tiene una fecha exacta de nacimiento.

Europa en el siglo XVI



Fuente: <https://colomabea.files.wordpress.com/2014/09/europa-carlos-v.jpg>

Con todo, se ha trabajado en el estudio de la génesis del estado moderno, sobre todo por autores franceses. La investigación ha evolucionado hacia la vinculación del origen del estado moderno con la implantación y explotación de un sistema capaz de satisfacer las necesidades de la fiscalidad del estado (como en el caso francés histórico). Así, siguiendo la definición de trabajo que hace Genêt, el estado moderno es:

«... un estado cuya base material reposa sobre una fiscalidad pública aceptada por la sociedad política (y esto en una dimensión territorial superior a la de la ciudad), y en la cual todos los súbditos están afectados por ella».

Jean-Philippe Genêt (1997). «La genèse de l'état moderne», *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, 118; 3-18 (pág. 3).

Algunas precisiones sobre la definición. De aquí se desprende lo siguiente:

- «Es un estado, es decir, una forma de organización social que, en nombre de su propia legitimidad, garantiza su propia seguridad y la de sus miembros/súbditos, y que dispone, al menos, para esta finalidad de un control, si no de un monopolio de la justicia y de una fuerza militar específica», si bien el hecho de disponer de un aparato judicial y de una fuerza militar no implica que automáticamente sea un estado moderno (puesto que «moderno» requiere determinados elementos y no se tiene que limitar al periodo cronológico homónimo).
- La «fiscalidad pública» presupone la existencia de un sistema de impuestos, con distinción de los ámbitos público y privado, y que no es completamente arbitrario.
- Que sea «aceptada por la sociedad» supone que haya diálogo (bajo cualquier forma), siquiera derivado de la guerra, elemento de cohesión altamente importante en la configuración de los estados modernos.
- «Sociedad política» entendida como sociedad civil.
- «Superior en la ciudad» porque históricamente en algunas ciudades había estos elementos, y ahora hay que vincularlos, diferencialmente, a las nuevas realidades territoriales (reinos...).
- «Todos los súbditos están afectados por ella» hace referencia a los individuos súbditos de la monarquía, a los cuales, ante la obligación de satisfacer los impuestos con cargo a sus bienes, se les está reconociendo, indirectamente, la propiedad de los bienes en cuestión.

Esta orientación hacia la fiscalidad conlleva centrar el origen del estado moderno en los siglos XIII-XIV, en concreto, en la franja de 1250 a 1350, en numerosos territorios europeos occidentales (Inglaterra, Escocia, Francia, Borgoña, Bretaña, Saboya, Castilla, Cataluña, Aragón, Navarra, Portugal), donde va tomando cuerpo esta manera de formar el estado, si bien con procesos, circunstancias y formas diferentes y variables entre sí. A partir de allí, el modelo se extendería a Alemania, Italia, territorios de la Europa central y Escandinavia.

Otro autor, Grossi, analiza los conceptos de cada momento histórico y afirma que no puede haber estado en la edad media porque en esta etapa el poder es esencialmente incompleto, inacabado, el derecho pertenece a la sociedad con una pluralidad de fuentes que no responde necesariamente al poder establecido y está estructurada en un tejido de autonomías. Afirma que el estado corresponde a la edad moderna. Lo argumenta así:

«El Estado, por lo que respecta a su contenido político-jurídico, es considerado por nosotros como un esquema de ordenación específico e inequívoco: una realidad rigurosamente unitaria, donde unidad significa, a nivel material, la efectividad de poder sobre un territorio garantizada por un aparato centrípeto de organización y coacción, y a nivel psicológico, una voluntad totalitaria tendente a absorber y a apropiarse de cualquier manifestación, al menos intersubjetiva, que se verifique en dicho territorio. Un macrocosmos unitario que se va configurando como una estructura global, provisto de voluntad omnicomprendensiva. El Estado, es decir, un sujeto político fuerte, la encarnación histórica de un poder político perfectamente acabado. [...] el Estado es una noción que posee un nicho histórico concreto, del cual no puede ser desligado si no es con arriesgada ligereza. De hecho, el terreno temporal que corresponde a dicho sujeto es sin duda el moderno, del cual representa quizás el fruto más llamativo e indudablemente también el más expresivo.»

Paolo Grossi (1997). «Un derecho sin estado. La noción de autonomía como fundamento de la constitución jurídica medieval». *Anuario Mexicano de Historia del Derecho* (núm. 9, págs. 169-170).

Y es una realidad propia de la edad moderna, con una peculiar dimensión que es la **soberanía** (tal como la definirá Bodin) que se convierte en el *leitmotiv* y la legitimación, y con la creación del derecho al servicio del poder. En esta época proliferarán los estados como sujetos políticos, en proceso de consolidación hasta el siglo XVIII, en que se puede considerar que el estado ya es creador y productor de todo lo que es jurídico, un estado legislador consciente de la relevancia política de todo lo que es jurídico y, así, **controlador** y **monopolizador**.

El estado tomó de la forma de organización precedente, propia de la Europa medieval (la monarquía cristiana), y de la herencia clásica griega y romana, sus elementos y nociones principales.

En este proceso de formación, los nuevos tiempos y los nuevos actores fueron dándole una fisonomía propia, y ocupaba en él un lugar principal que el derecho pasó a ser, se convirtió, en el eje vertebrador del poder político.

Ya hemos apuntado que el estado es un complejo estructural que se fue formando alrededor de las instituciones monárquicas desde el siglo XIII, y que lo iría haciendo al compás de los tiempos hasta el siglo XX. En este sentido, el estado moderno no puede ser anterior a la Baja Edad Media, e irá evolucionando, hasta el absolutismo, con su caída a finales del siglo XVIII y, con una nueva fisonomía, con la entrada en escena, al inicio del siglo XIX, del estado liberal fruto de la revolución burguesa.

Hacia el final de la Baja Edad Media ya había habido una variada, lenta y compleja evolución en varios ámbitos que había ido conformando unas nuevas bases para una nueva organización política. Conviene tener muy presente que el resultado de esta evolución fue dilatado en el tiempo (especialmente entre los siglos XIII y XV), complejo en la concreción, y diferente según los territorios

(con casos destacados, como Francia o Inglaterra, en comparación con el caso peninsular, por ejemplo), o el alemán y que fue a partir del siglo XVI que se consolidó y desarrolló.

Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista historiográfico hay una manera relativamente extendida, sobre todo a escala internacional (por ejemplo, en los ámbitos anglófono y francófono), de referirse a estos monarcas como monarcas de los territorios actuales equivalentes, en una clave de visión «nacional» contemporánea (francesa, inglesa, etc.) proyectada en el pasado.

Estos autores se refieren a la realidad histórica de los territorios peninsulares con este mismo planteamiento, si bien debemos tener presente que, a diferencia de esos territorios europeos citados (homogéneos y con una frontera), los territorios peninsulares, Portugal aparte, tenían títulos y personalidades jurídicas diferentes (heterogéneos, con diferentes ordenamientos jurídicos y diversas fronteras), si bien una sola persona, un solo monarca, era el único titular de todas las coronas¹.

⁽¹⁾Esta forma de gobierno ha sido denominada **monarquía compuesta o estado compuesto** por reconocidos estudiosos de la edad moderna como Helmut G. Koenigsberger, Conrad Russell o John H. Elliott, y, consiguientemente, tienen en cuenta dichas circunstancias en sus estudios.

No debería causar sorpresa, pues, que principalmente a escala internacional, pero no únicamente, haya quien hable de Alfonso X como rey de la *medieval Spain* (sin precisar que era rey de Castilla, y que el conde de Barcelona y rey de Aragón y de Valencia era entonces otra persona), o que se hable de la *Espagne moderne* (sin distinguir los diferentes reinos peninsulares). Tratándose de autores de territorios pioneros en el estudio de la consolidación del poder del monarca y de las estructuras estatales en clave nacional, no debe extrañarnos que autores ingleses y norteamericanos, y autores franceses, entre otros, apliquen a la visión histórica de otros territorios su «lógica nacional» actual.

El cuidado y la precisión terminológica aplicados al caso peninsular reclaman precaución en la utilización de los términos. Así, en cuanto a los territorios hispánicos, conviene recordar que la aparición del estado moderno y la acumulación de coronas en un solo titular, el rey de Castilla, no supuso la unificación o uniformización políticas ni jurídicas de los diversos reinos, pese a los intentos de la monarquía en la edad moderna en esta dirección. Como veremos, habrá que esperar hasta el régimen de la Nueva Planta (desde 1715-1716) para que haya una igualación de los súbditos de la monarquía al modelo castellano, y una integración, no solo territorial, de todos los reinos de la antigua Corona de Aragón en la Corona de Castilla, con un único monarca que acumulaba todos los títulos, ahora ya, sin embargo, de manera honorífica (puesto que, como acabamos de decir, las coronas a las cuales se referían habían sido incorporadas en el reino de Castilla). Con todo, todavía habrá que esperar hasta el siglo XIX, a la Constitución de 1812, para poder hablar con propiedad de una **nación española** y de España entendida como tal, como una nación, y no como un mero descriptor toponímico, derivado de la vulgarización en las lenguas románicas peninsulares del término geográfico latín *Hispania*.

2.2. Teorización, autores

La idea de estado iba tomando forma y cuerpo por la vía de hecho y también de la mano de múltiples contribuciones teóricas, con una lista de autores con nombres como por ejemplo Tomás de Aquino (1225-1274), Maquiavelo (Niccolò Machiavelli, 1469-1527), Jean Bodin (1529-1596), Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Jean-Jacques Rousseau (1712-1776), o John Stuart Mill (1806-1873), entre otros, de los cuales destacamos algunos.

Para **Tomás de Aquino** (s. XIII), la ciencia política captaba la estructura natural y el sistema de la sociedad y edificaba un «estado» o una sociedad política completa, según las normas naturales que esa realidad dictaba por el solo hecho de ser. En este sentido, el derecho positivo emanaba del derecho natural como la naturaleza normativa de la sociedad. El derecho y la sociedad política tendrían que cumplir los fines naturales del bienestar humano y, así, el universo político se volvería autónomo, de tal manera que toda fuente de poder provendría de Dios. Cada sociedad, reconociendo lo que era natural o nacional (*natio*) frente a lo que era universal e imperial (*gens*), se organizaría de la manera más idónea para poder lograr sus finalidades. Bebiendo de Aristóteles y de la observación de la evolución del mundo, cree que la estructura política terrenal, sometida al poder espiritual, está dirigida a obtener el bien común.

Maquiavelo (s. XV-XVI) es visto como uno de sus precursores. Siguiendo los caminos iniciados por Aristóteles y Tomás de Aquino, fue el primer autor que trató con aspiraciones científicas la política, introdujo el sentido actual del término **estado** y estableció las bases ideológicas de lo que sería la moderna teoría del estado. De este modo, y con estas aportaciones, se entró en una nueva fase, con un nuevo apoyo teórico de lo que sería la nueva realidad estatal. Para Maquiavelo, el estado sería una estructura ordenada, perfecta, a partir de la cual lograr el orden y poder organizar la vida social adecuadamente, de tal manera que se estabilizara y a la vez se garantizara la seguridad, donde todo estuviera previsto por su poder supremo (autónomo de otros poderes); poder que tendría, además, el monopolio de la fuerza y del derecho. Para poder llevarlo a la práctica, si hacía falta, se tendría que recurrir a otros conceptos y principios como por ejemplo:

1) **la razón de estado**: concepto que se acabaría de elaborar en los siglos XVI-XVII y que conllevaría una **racionalidad específica** en el gobierno de los estados y en sus objetivos;

2) **la fuerza**: necesaria para garantizar el orden hacia el interior, y, hacia el exterior, para defenderse ante otros estados y a la vez asegurar la supervivencia del propio, y

3) **la idea de unidad**: principio común que se manifestaba en dos vertientes: por un lado, la unidad referida al estado y al colectivo de población que este representaba, y, por el otro, la unidad concebida alrededor de la figura del príncipe, que tendría el mando del estado y también el de la fuerza y del derecho, que dependería de su voluntad.

Algunos autores, en este punto, presentan el estado como un elemento aglutinador, unificador, de un conjunto determinado de población que tiene seguridad por la certeza del derecho de forma que, consideran, con estas características se superaría la sociedad medieval.

En cuanto a **Jean Bodin** (s. XVI), su gran aportación al proceso de formación de la teoría del estado² fue su teorización del nuevo concepto de **soberanía**, recogida en su obra *Les six livres de la République*. Para él, la soberanía deviene el elemento central, un poder absoluto en manos del príncipe, un poder perpetuo, invisible en el contexto de lo que él denominaba una **república** (es decir, de un estado), que se manifestaba como poder supremo –y desligado de las leyes– y se ejercía sobre los súbditos de la monarquía por parte del príncipe o monarca.

⁽²⁾La formación de la teoría del estado se profundiza en el apartado «La teorización de la soberanía en el siglo XVI: Jean Bodin» del presente módulo.

2.3. Cambios estructurales

Además de los aspectos teóricos del nuevo estado y de la supervivencia de elementos existentes que adoptarían un nuevo carácter –como la misma monarquía–, lo que hay es un verdadero **cambio estructural**, un cambio notable respecto del periodo precedente. Este cambio aspiraba a dar respuesta a las nuevas necesidades, que ya hemos apuntado:

- numerosas y extensas posesiones territoriales,
- diferentes coronas acumuladas en una sola persona,
- aumento consiguiente del número total de naturales (o súbditos) y de los mecanismos impositivos y de control,
- nuevos flujos comerciales,
- intereses políticos internacionales,
- etc.

Precisamente por eso, la nueva estructura estatal comportó el abandono de una serie de maneras de hacer desde el punto de vista político y de administración, más propias de la visión del mundo medieval y de su gestión, para establecer otras nuevas, más modernas. Se dejaron a un lado, pues, las prácticas heredadas de un mundo feudal. Unas prácticas a menudo perpetuadas por miembros de familias nobles que ocupaban, hereditariamente desde hacía generaciones, cargos de confianza del monarca. Consiguientemente, se adoptaron prácticas nuevas, centralizadas en las nuevas estructuras administrativas renovadas bajo la responsabilidad de **oficiales y cargos profesionales** (lo que hoy denominaríamos funcionarios de carrera).

Los nuevos oficiales del rey se hicieron cargo de los asuntos políticos, financieros, judiciales y legislativos de la monarquía. Se trataba de oficiales debidamente formados desde el punto de vista profesional (en los estudios generales de derecho), y con una clara tendencia a establecer procedimientos cada vez más técnicos y gradualmente más uniformes. Una tendencia a la uniformización que impregnaba los diversos ámbitos de actuación del estado y de la monarquía alrededor de la cual se estructuraba (fortaleciéndola), hasta el punto de que la tarea de estos oficiales se hizo clave en la evolución de las estructuras estatales y esencial para la monarquía absoluta y la consolidación del absolutismo regio. En este contexto, la gestión de los asuntos de gobierno fue evolucionando hasta tener, por ejemplo, en el caso de las imposiciones fiscales –es decir, la recaudación de impuestos–, una verdadera fiscalidad de estado.

Fiscalidad de estado

En el reino de Francia, por ejemplo, como en otros territorios (el reino de Castilla o el Principado de Cataluña), desde los siglos XIV y XV, el poder real se fue amparando del monopolio de la percepción de los ingresos fiscales, de las levatas militares y de la iniciativa política. Este hecho es lo que permite decir a algunos autores, como ya hemos visto, que la fiscalidad de estado es un rasgo característico y definitorio del estado moderno.

En cuanto al nuevo carácter de la monarquía, desde el inicio del periodo en que se fue empezando a formar el estado, podemos citar varios monarcas europeos bajomedievales que ejemplificaron el nuevo carácter de la monarquía:

- Federico II en Alemania y en Italia (1194-1250),
- Jaime I en la Corona de Aragón (1208-1276),
- Alfonso X en el reino de Castilla (1221-1284), o
- Felipe IV en Francia (1268-1314).

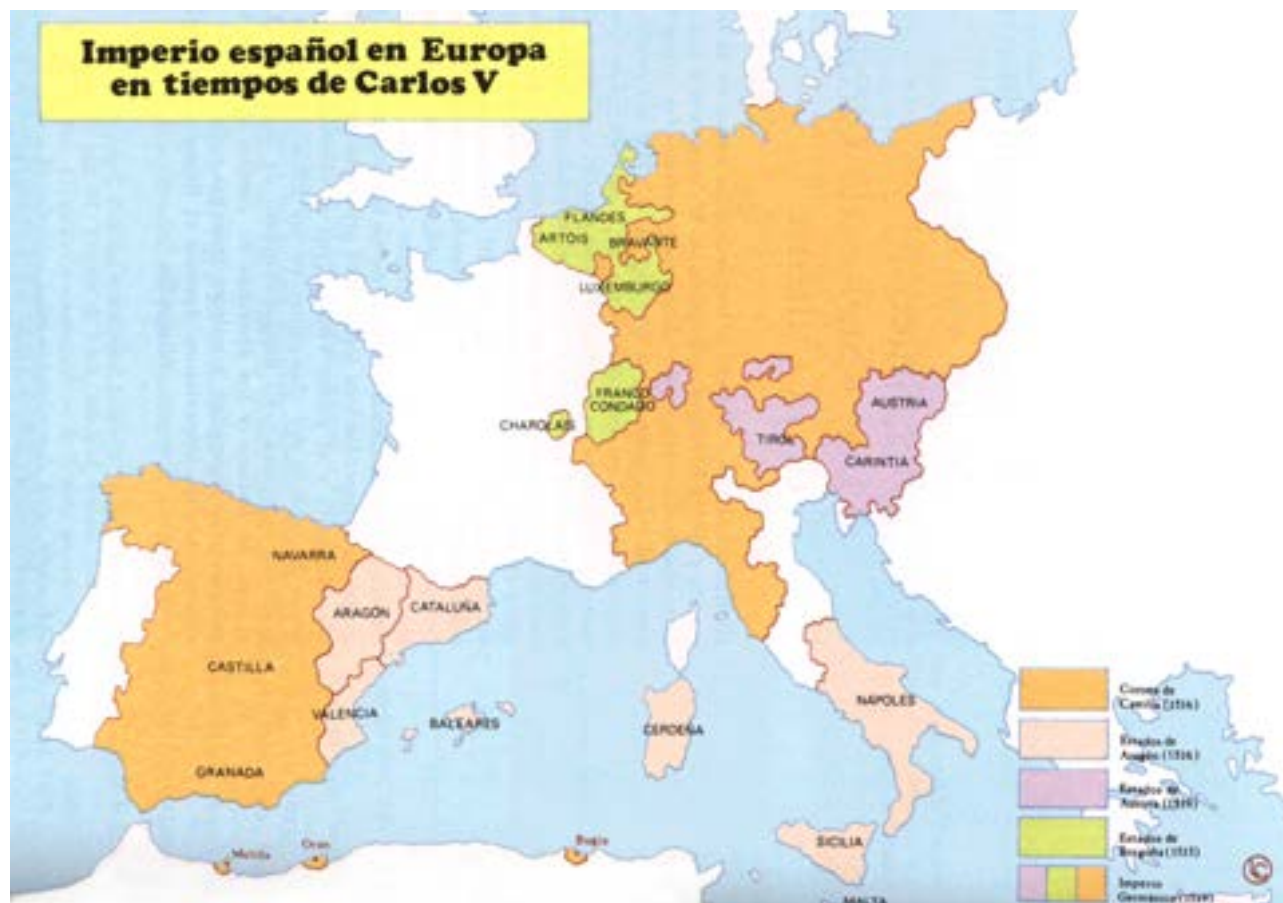
Una monarquía que dejó una impronta que sus sucesores fueron continuando y ensanchando, tanto como se lo permitieron las circunstancias. El rasgo común que compartieron y nos interesa destacar es que todos ellos se convirtieron en una figura monárquica fuerte y decidida, que se quería imponer a los estamentos de sus reinos y que se acabó imponiendo. Una figura que, originaria del mundo feudal y del conjunto de limitaciones que este mundo feudal imponía desde la misma base de los privilegios feudales que debían ser respetados, fue evolucionando hacia un ejercicio del poder que, cuanto más se acercaba la edad moderna, más tensiones generaría; tensiones producidas por la evolución de la sociedad y de las formas de actuar, también políticas, que evidenciaban la necesidad de un cambio, que, en el ámbito político, podemos considerar ejemplificado por la **teoría política de Bodin**.

Por lo que respecta al nuevo carácter de la monarquía de la edad moderna, la variación que hubo fue tender a afrontar las problemáticas globales del nuevo mundo moderno tratando de liberarse de los vínculos medievales. Buena parte de las tensiones y conflictos de los siglos XVI y XVII, especialmente en los territorios de la península ibérica, encuentran ahí su origen.

Una manera de verlo es considerar que su origen radica en la diferente visión que tenían, en la edad moderna, por un lado, el rey y sus oficiales, y, por el otro, los naturales del monarca de un determinado territorio (por ejemplo, los castellanos, los catalanes, los aragoneses, los navarros...). La visión del rey y de sus oficiales era una visión global, de quienes poseen varios territorios y tienen conflictos y problemas de gran alcance geográfico o gran repercusión. Por el

contrario, la visión de los segundos (los naturales de cada reino) se correspondía con un marco geográfico, por comparación, más reducido y se basaba en defender sus derechos a partir del privilegio feudal y de la sociedad estamental (en la cual, recordémoslo, se basaba también el poder monárquico) desde una óptica de «reino».

Imperio de Carlos I



Fuente: http://redgeomatica.rediris.es/ecai/atlas_iberomundo/mapas_iberomundo/imperio_europa.gif

Esta diferencia de perspectivas hacía que, comparativamente en relación con el rey y su círculo, la visión de los estamentos tuviera una óptica geográficamente más próxima, directa, reducida, sectorial, regional (y para algunos autores restringida, limitada), mientras que la del monarca, ensanchada y geográficamente amplia, llevaba a no prestar la misma atención a los problemas de dimensiones comparativamente más reducidas o ámbitos geográficos menos extensos y, en consecuencia, dar preferencia a los que se consideraban los grandes problemas de la monarquía (que, para otros autores, no era otra cosa que descuidar las peculiaridades de los reinos para favorecer los grandes dominios).

Sobre estos presupuestos, se comprende mejor la problemática que el conde-duque de Olivares (valido del rey Felipe III de Cataluña y IV de Castilla de 1622 a 1643), con su proyecto conocido como la **Unión de armas**, planteó en el ámbito político y jurídico cuando esperaba de los catalanes (y de los castellanos, aragoneses, valencianos, portugueses, milaneses, mallorquines, etc.), «como súbditos de la monarquía», que armaran un ejército para ir a defender Flandes, negligiendo que los catalanes (y también los otros naturales de otros territorios del monarca), desde el punto de vista de ellos, «no eran

súbditos de la monarquía», sino que eran los naturales de su señor natural, en este caso, el conde de Barcelona [= rey], rey de Aragón, rey de Valencia..., y que su **derecho propio** solo obligaba, por ejemplo a los catalanes, a armar un ejército cuando se encontraba en peligro el territorio del Principado y los condados de Rosellón y Cerdaña. Así lo establecía el derecho del Principado en el *usatge Princeps namque*, que el monarca había jurado observar y hacer observar al ser entronizado. A partir de aquí, el entendimiento no sería fácil, y, al final, este no se produjo.

En cuanto a las fronteras, este nuevo carácter se reflejó también en la concepción misma del territorio y sus límites, en las fronteras. Las fronteras existían desde la antigüedad, con mayor o menor definición, aprovechando accidentes geográficos naturales o, incluso, reforzadas con construcciones humanas (pensemos, por ejemplo, en las fortificaciones hechas por los romanos en los *limites* –o fronteras exteriores– del Imperio, como el *limes Germanicus* en el continente, o el muro de Adriano en Britania).

Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, las fronteras tuvieron límites no siempre tan claramente delimitados, salvo que coincidieran con accidentes naturales, pero cumplían de manera bastante satisfactoria su función, a la vez que se había ido consolidando el poder político en cada territorio a lo largo de la época medieval. Con el afianzamiento de los estados, las fronteras fueron ganando relieve, y revalorizaban el papel del territorio del reino en cuestión, que, a su vez, se iría convirtiendo en una realidad más compacta a medida que se acercaba la edad moderna.

Los reinos de Inglaterra, de Hungría y de Dinamarca, por ejemplo, modernizaron su organización política desde una óptica que hoy denominaríamos **nacional**, mientras que el caso francés fue diferente y no se completó la unificación territorial hasta finales de la Baja Edad Media y muy entrada la edad moderna, según los territorios progresivamente anexionados.

Así, por ejemplo, Borgoña en 1477, Provenza con Luis XI en 1481, Bretaña en 1532, Rosellón en 1659 –en virtud del Tratado de los Pirineos–, el Franco-Condado en 1678, e incluso otros a finales del siglo XVIII (Lorena, Córcega), si bien hay que tener presente que no regiría en todos ellos un mismo derecho hasta el comienzo del siglo XIX con el *Code civil* de Napoleón en 1804.

El caso de los reinos peninsulares todavía fue más tardío y singular, puesto que no se acumularon todas las coronas en una sola persona hasta los siglos XV y XVI con Juana I, hija de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, y teniendo presente que cada reino siguió manteniendo su propia identidad diferenciada, tanto política como jurídica, y con las respectivas fronteras establecidas y los correspondientes pagos de los derechos de aduana por el paso de mercancías. El caso alemán también fue peculiar, por la subsistencia en el tiempo de los principados. Igualmente lo fue el caso holandés, que no tuvo entidad de reino hasta el siglo XIX. El caso italiano también fue bastante singular, vinculado indefectiblemente a la evolución de las ciudades-estado medievales y a sus príncipes.

2.4. Transformación de los órganos centrales del estado: gobierno por consejos y administración

La transformación de los órganos centrales del estado devino igualmente evidente, por los incrementos de necesidades, que generaban nuevas estructuras, las cuales reclamaban un número más elevado de oficiales a su servicio.

Paralelamente, hubo una mayor y mejor preparación vinculada a la profesionalización y a la especialización de los cargos de la administración del estado. También hubo una centralización cada vez más considerable y, en último lugar, aunque no por ello menos importante, hubo una burocratización evidenciada por la tecnificación de los procedimientos y de la documentación, congruentes con la formación recibida en los estudios de derecho por los miembros que formaban este nuevo colectivo de oficiales con responsabilidades administrativas y de gobierno, juristas de formación, que ocupaban los cargos, con denominaciones diversas, según los territorios (por ejemplo, letrados, asesores, abogados...).

Las nuevas circunstancias supusieron, pues, la aparición de instituciones y cargos al servicio de la monarquía que debían conjuntar, por un lado, dar solución o respuesta a los nuevos problemas de la época desde la óptica del estado y de los intereses de la monarquía (lo que sí podrían hacer), y, por el otro, encajar, sobreponiéndose a ello, en la realidad heredada de la Baja Edad Media, sin dejar desatendidos a los naturales de cada uno de los reinos de la monarquía (lo que ya les costaría bastante más hacer, por el conflicto latente de intereses, por un lado, entre el monarca como cabeza de un estado en un marco interno complejo, y también internacionalmente, y, por el otro, los propios y tradicionales de cada reino y estamentos).

En definitiva, el proceso fue revirtiendo en una estructura institucional cada vez más compleja y articulada; en una formación cada vez mejor de los oficiales –a menudo procedentes de linajes influyentes– y en una burocratización progresiva de la administración, del aparato administrativo estatal, si bien debe distinguirse, a grandes rasgos y sin entrar en muchos detalles en cuanto a la venta de cargos y oficios, entre los oficios de justicia y los demás (afectó principalmente a escribientes, oficios municipales y recaudatorios), puesto que los primeros, en el ámbito de la justicia, se vieron menos afectados por la venta de oficios. Esta situación fue propia del mundo sobre todo moderno, y se produjo en muchos de los territorios europeos. Con los años, y cuanto más avanzaba la edad moderna, más medidas de reconducción de la situación se llevaron a cabo, para recuperar los oficios inicialmente vendidos y reforzar el proceso de recuperación de las regalías del monarca.

2.4.1. Gobierno por consejos

En cuanto al **gobierno por consejos**, en el contexto europeo de intereses internacionales, de afianzamiento de los monarcas y de consolidación de las extensiones territoriales de los grandes reinos, la complejidad de gestión de los intereses del estado moderno (e indirectamente de la monarquía) conllevaba la necesidad de crear órganos que ayudaran a ello. Además de una primera razón puramente técnica, que se explicaría por la facilidad de gestión, propia de la especialización de los nuevos órganos y de sus miembros, podía haber también otras causas coincidentes. El caso de la monarquía hispánica derivó en una estructura de gobierno por consejos particular, dada la singularidad de la misma monarquía que acumulaba todas las coronas de los reinos peninsulares con personalidad política y jurídica diferenciadas, en contraste con otros territorios europeos donde no se producía tal singularidad (como por ejemplo en Francia o en Inglaterra).

Así, un ejemplo del primer caso podría ser el de los monarcas hispánicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, al crear diferentes consejos para facilitar la gestión de sus diversas coronas. En los reinos hispánicos, para agilizar la tramitación de la documentación y también para paliar el alejamiento del monarca de sus territorios, desde finales de la Baja Edad Media se generalizó, por parte de la monarquía, el gobierno de los territorios de los cuales el monarca era titular mediante la creación de consejos *ad hoc* (es decir, **específicos**, especializados en sus asuntos) para que le asesoraran a la hora de tomar las decisiones de gobierno pertinentes. Estaban constituidos por personas de su confianza procedentes, en su caso, de los territorios en cuestión.

Por eso, el hecho de que el monarca gobernara cada territorio suyo con la ayuda de un consejo específico que conociera el reino –el llamado **gobierno por consejos**, también llamado **régimen polisinodial** por algunos autores– se fue generalizando y extendiendo en el tránsito del siglo XV al XVI, con reformas graduales importantes en su régimen.

El papel y el funcionamiento de los consejos de la monarquía hispánica han sido sintetizados así:

«Los diferentes consejos que componía el gobierno de la monarquía eran el eje sobre el cual giraba la administración de la misma. La necesidad y obligación de consulta por parte del rey que se había desarrollado a lo largo de la edad media se institucionalizó en una serie de organismos independientes entre sí y con competencias más o menos determinadas que ayudaban al rey en su ardua labor. Estos órganos colegiados se componían de diferentes presidentes, gobernadores o regentes que dirigían una serie de asesores letrados y de capa y espada cuya proporción variaba según los diferentes consejos y que se rodeaban en una amplia capa de secretarios, escribanos y oficiales que eran la verdadera savia de estas instituciones. A través de la consulta, informe que los diferentes consejos elevaban al rey, la voz de los consejeros era escuchada por el monarca, quien siempre, no obstante, se reservaba la última palabra en cualquier asunto, incluso en contra de las opiniones de sus burócratas si así lo quería.»

Enrique Martínez Ruiz (dir.) (2007). *Diccionario de historia moderna de España. II. La administración* (págs. 114-115).

Además del Consejo de Castilla (desde finales del siglo XIV, con Juan I), podemos citar el Consejo de Estado (desde 1526, con Carlos V), el Consejo de Aragón (desde 1494, con Fernando II e Isabel I), el Consejo de Indias (desde 1524, con Carlos V) o el Consejo de Italia (desde 1556, con Felipe II, que separó sus asuntos de los de Aragón), el de Portugal en 1582 o el de Flandes en 1588, entre otros. Así, los dedicados a los territorios de que el monarca era titular ayudaban a gestionar, con cierto grado de conocimiento, la gran extensión de los dominios de la monarquía, pero también había consejos específicos de otro tipo, en función de la **materia**, como por ejemplo el Consejo de Guerra, el Consejo de la Inquisición (los dos de finales del siglo XV) o el Consejo de Hacienda (de comienzos del siglo XVI).

Un ejemplo del segundo caso podría ser el caso francés, con Luis XIV, que con Colbert, en el siglo XVII, reformó y burocratizó la administración y centralizó los órganos de gobierno, reformó el Consejo del rey (el *Conseil du roi*) y diversas secretarías de estado (casa del rey, asuntos extranjeros, guerra, asuntos religiosos), a la vez que neutralizó la nobleza, y dejó la gestión de la administración territorial en manos de los **intendentes** (oficiales controlados directamente por el rey). Las reformas del Consejo del rey de Luis XIV quedaron establecidas en cuatro secciones (el *Conseil d'en Haut* o *Conseil d'État*, desde 1643, formado por los ministros que convocaba el rey a voluntad; el *Conseil des Dépêches*, desde 1650; el *Conseil des Finances*, desde 1661; y el *Conseil d'État privé, finances et directions*). La figura del **secretario de estado** se correspondería con lo que serían los ministros actuales. En el caso de Castilla, deberá esperarse hasta el siglo XVIII para encontrarlos, como **secretarios de Estado y del Despacho**, con las reformas, en vigor hasta 1833, introducidas por Felipe V después de la implantación del régimen de la Nueva planta.

En Inglaterra, la importancia del Parlamento y, sobre todo, la preeminencia del rey con el Parlamento como institución suprema, en los temas legislativos tuvo que coexistir con los intentos y las actuaciones frecuentes del rey con su consejo (el *King's council*, y, desde la reforma administrativa burocratizadora de los Tudor a mediados de siglo XVI, *Privy council*). Se redujo considerablemente el número de miembros del consejo a una veintena, especializados y con el consiguiente reparto institucional de tareas, para favorecer su funcionamiento y evitar prevalencias internas, puesto que se había convertido en el núcleo del sistema estatal de gobierno de la monarquía Tudor.

El reparto, complejo, de funciones entre las instituciones del estado descansaba en buena medida en un hecho común en otros muchos territorios, donde ocurría prácticamente lo mismo que en Inglaterra: el Parlamento inglés (o la asamblea de que se tratara) se reunía ocasionalmente, mientras que el *council* del rey (o el consejo de que se tratara) se reunía cada día para abordar tareas de gobierno. De este funcionamiento se desprendió no solamente una especialización, sino también una profesionalización, hasta el punto de que, desde entonces, se puede empezar a hablar de una novedad que se manifestaba en la



El rey de Francia con su Consejo.
Fuente: http://passerelles.bnf.fr/images/3/pas_200.jpg

gradual toma de conciencia por parte de los miembros del *council* como **servidores del estado** más que como **servidores privados del monarca**, situación, esta, más propia de los tiempos anteriores y del periodo netamente medieval.

2.4.2. Instituciones de la monarquía, de los reinos

En la edad moderna, en el ámbito peninsular, estos cambios coincidieron también con el hecho de que la corte del monarca, que había sido itinerante hasta 1522, cuando se había establecido en Toledo, se trasladó para establecerse en Madrid. Fue en 1561, en el reinado de Felipe II, que acumulaba todas las coronas peninsulares, y solo hubo un paréntesis, de 1601 a 1606, cuando se fue a Valladolid por intereses del duque de Lerma. Cuando hacía falta, el monarca y su cortejo se desplazaban por tierras de Castilla y en especial a otros territorios además del castellano, por cuestiones estrictamente políticas, o bien para celebrar, por ejemplo, una asamblea parlamentaria (cortes, *corts*...). En los territorios franceses, por el contrario, la monarquía del Renacimiento era todavía itinerante, si bien cada monarca tenía sus castillos o lugares preferidos. Francisco I (1515-1547) construyó a comienzo del siglo el castillo de Chambord, a mediados de siglo el de Fontainebleau y recurrió también, a partir de 1539, al Louvre para recibir embajadas. Caterina de Médici declaró París residencia principal de la corte desde 1566. No fue hasta Luis XVI cuando, desde 1673, se edificó Versalles, sede de la corte y verdadero *chateau d'État*.

Pese a esta estructura, y teniendo en cuenta que en el siglo XVII hispánico se agravó la relación entre el monarca y algunos de sus territorios de la Corona de Aragón, la evolución de los mecanismos administrativos de la corte de Madrid no tendió hacia la simplificación. Recordemos, por ejemplo, el papel que tenían los consejos en el siglo XVI, donde predominaba la figura del **secretario**, que gestionaba los asuntos del consejo. Era un cargo dependiente del monarca, mientras que en el siglo siguiente el papel creciente lo fueron teniendo en el ámbito administrativo –y el correlativo peso político que comportaba– no tanto los secretarios sino los **validos**, que despachaban directamente con el monarca y daban órdenes en su nombre (por ejemplo, el duque de Lerma, o el conde-duque de Olivares, en el siglo XVII).

En los diversos territorios, junto a las instituciones del reino y a las instituciones municipales, el monarca tenía su (propia) administración. Esta **administración real** en los territorios donde el rey no residía habitualmente estaba formada por personas de su confianza.

Estando el virrey como representante del rey, en teoría, pues, tendría que haber bastado tramitar las peticiones al rey de particulares o de instituciones mediante la estructura administrativa del monarca en el reino en cuestión, puesto que los oficiales del monarca en el reino se tendrían que encargar de hacer llegar el escrito, debidamente informado, a Madrid, para que se tramitara y se resolviera. Vistas las dificultades y la lentitud de resolución, a menudo el mecanismo habitual elegido por muchas instituciones y algunos particulares con recursos acabó siendo enviar a la corte de Madrid una **embajada** (es decir, una o más personas en representación suya) con encargos específicos para gestionarlos y tramitarlos. Enviar una embajada a la corte quería decir enviar una persona o un conjunto de personas escogidas encargadas de gestionar un asunto determinado ante una instancia administrativa determinada para obtener, si era posible, una respuesta satisfactoria. Con

Instituciones en Cataluña

Son ejemplos de instituciones del reino en Cataluña: la **Diputación del General**; de institución municipal, en Barcelona, el **Consejo de Cien Jurados**; de administración del monarca, el **virrey** o la **Real audiencia**. El virrey representaba al rey mientras no estaba en el reino; la Real audiencia era el órgano encargado de administrar justicia en nombre del rey.

todo, la complejidad progresiva de las estructuras administrativas y la burocratización creciente, a menudo, derivaban en una situación bastante compleja de gestionar y más larga de lo que se esperaban los enviados, y con un resultado, si se llegaba a alcanzar, a menudo bastante menos exitoso de lo que se habría querido. El alud de embajadas en Madrid hizo que, a lo largo de la edad moderna, se dictaran normas que las limitaban y las regulaban.

En otros territorios europeos, la progresión de los intereses de la monarquía se tenía que acompañar con los condicionantes y las características propias. En Francia, pionera en el proceso designado como la génesis del estado moderno y absoluto, por ejemplo, el refuerzo del poder monárquico en tiempos de Luis XIV fue posible gracias a la unificación religiosa, al debilitamiento de los poderosos y al afianzamiento de la monarquía ante los *parlements*.

Cabe decir que un paso previo importante llevado a cabo entre mediados del siglo XV y a lo largo del XVI para reforzar la monarquía francesa había sido la redacción oficial de las **costumbres** de los territorios de *droit coutumier*. La burocratización había supuesto una mejora sensible de la organización estatal. Esta mejora se hizo patente, desde el punto de vista cuantitativo, con un aumento de los cargos y oficiales y, desde el punto de vista cualitativo, con un incremento en la efectividad de los servicios.

Pays de droit écrit y pays de droit coutumier



Fuente: https://www.cairn.info/loading.php?file=hsr/hsr_026/hsr_026_0169/hsr_id2868478190_pu2006-02s_sa06_art06_img001.jpg

La complejidad administrativa y procedimental de las diversas instancias de gobierno hizo del aparato estatal un ente con unas dimensiones y unas necesidades propias, como sucedió también, a otro nivel, con las instituciones del reino (por ejemplo, la Diputación del General, o, en el ámbito municipal, los órganos rectores, o en el ámbito eclesiástico o señorial). La centralización, no solo geográfica de los órganos de gobierno del estado, implicó que la élite de los oficiales y cargos al servicio de la monarquía y el propio monarca fueran teniendo, cada vez más, una visión más general, más global, de sus territorios (independientemente de su localización geográfica concreta –Cataluña, Aragón, Flandes, Rosellón, por ejemplo–) y fueran perdiendo de vista las peculiaridades y características, incluidas las jurídicas y políticas, de cada uno de estos

Parlements

Parlements es el nombre con que en Francia se designaban unos altos tribunales de justicia real, con atribuciones, entre otros, de control de la legislación. No deben confundirse con las asambleas estatales de tipo parlamentario, que en los territorios franceses se llaman *états*.

Derecho consuetudinario y derecho escrito

Recordemos que los territorios franceses habían tenido dos *tradiciones* jurídicas, que los habían dividido entre los que se basaban en las **costumbres** (*coutumes*), llamados territorios (o *pays*) de *droit coutumier* –es decir, de derecho consuetudinario–, y los territorios (o *pays*) de *droit écrit* –es decir, de derecho escrito–, los que se basaban en el **derecho de la recepción**, del *ius commune*.

otros territorios de los cuales el monarca también era titular del poder político; de ahí que se fueran alejando de ellas, aspecto que podemos relacionar, junto con otros factores específicos, con los orígenes de varios conflictos propios de la edad moderna.

La gestión de los intereses de la monarquía, de su círculo de influencia y del estado, en la edad moderna, a menudo supuso fricciones y crisis relacionadas con otros reinos del mismo monarca, además de los conflictos internacionales. En la medida en que los reinos tenían y conservaban su propia personalidad política y su propio ordenamiento jurídico, las vías de solución a los conflictos planteados no siempre permitieron una resolución pacífica ni satisfactoria para los intereses de estos territorios.

Así pues, de hecho, acabó quedando abierto el camino hacia el afianzamiento de la soberanía del monarca e, indirectamente, abierta una vía de evolución hacia el absolutismo regio que, en la península ibérica, tuvo un amplio crecimiento y rasgos peculiares a partir del siglo XVIII, después de la Guerra de Sucesión.

2.5. La teorización de la soberanía en el siglo XVI: Jean Bodin

La teorización del absolutismo contó con varias aportaciones, muchas de ellas menores y circunstanciales, coetáneas del reinado de Luis XIV. Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), destacado partidario de la monarquía como forma de gobierno, y del absolutismo monárquico y del poder de origen divino del rey (por delante del poder del pontífice de Roma), afirmaba que la autoridad del rey se caracterizaba por que era sagrada, paternal, absoluta y sometida a la razón.

Con anterioridad, Thomas Hobbes (1588-1679) había defendido la monarquía autoritaria, la cual tendría que recaer en una sola persona (o figura): el *Leviathan*, si bien con esta teoría no llegó a complacer a los partidarios del absolutismo de derecho divino. La vida común se basaría en un contrato social, garantizado por la soberanía, de forma que, para él, la soberanía no descansaría en el derecho divino, sino en el mantenimiento del contrato social que la generaba.

Con todo, el autor que ha tenido más trascendencia desde el punto de vista de la historia política y la historia del derecho ha sido un autor anterior a los dos precedentes: **Jean Bodin (1530-1596)**. Desde que Bodin elaboró el nuevo concepto de soberanía y lo teorizó, se puede ver la historia política y jurídica de los diversos territorios europeos occidentales dentro de una evolución que acabará desembocando en el absolutismo.

Absoluto

El uso del término **absoluto** referido al poder, al monarca o a la monarquía tiene que ver con su etimología. Viene del latín *absolutus*, de *absolvere*, y este de *solvere*, 'desatar'. Es decir, inicialmente se usa el adjetivo «absoluto» para calificar el poder del rey, el monarca o la monarquía que no está vinculado, que no está atado, que no tiene limitaciones. Será con el paso del tiempo que acabará teniendo un **sentido peyorativo** por los abusos de poder que hubo en el Antiguo Régimen.

Su obra fue capital, un referente, un hito que marcó un antes y un después en el plano teórico y conceptual. Otra cosa fue la posibilidad real de llevar a cabo sus postulados, de llevarlos a la práctica, que varió, y mucho, en función de los territorios europeos de que se tratase y de las circunstancias de cada uno en cada momento histórico.

Con calendarios y en circunstancias diferentes según los territorios, dejando aparte el caso inglés (en Francia bastante rápidamente, en Castilla en el siglo XVIII, por ejemplo), se llegó a un nuevo modelo –la **monarquía absoluta**– que pudo poner en práctica los postulados teóricos de esta nueva soberanía por lo que respectaba a la libertad de actuación del monarca, es decir, sin limitaciones, prácticamente de ningún tipo, especialmente, las provenientes de los vínculos medievales de la monarquía con los estamentos (tanto en lo que se refería a sus intereses como, sobre todo, en lo que se refería a los privilegios de sus naturales).

La afirmación de esta novedad conceptual, de entrada, permite plantear la cuestión de si antes de Bodin había soberanía. Antes de la teorización de Bodin, la forma con que los juristas designaban el poder de que disfrutaban los monarcas, el conjunto de atribuciones de la monarquía, era recurriendo a expresiones como *potestas*, *summa potestas*, o *plenitudo potestatis*. Con estos términos describían el poder genéricamente o se referían a él globalmente, mientras que cuando se querían referir a atribuciones concretas de los monarcas, los juristas medievales hablaban de las *regalías* de su majestad (como por ejemplo, convocar la asamblea parlamentaria, acuñar moneda o hacer leyes).

Para no tener que remontarnos hasta la época romana, podemos considerar que esta evolución conceptual en relación con el ejercicio del poder arranca, sobre todo, de los precedentes de las monarquías bajomedievales en las que los reyes usaban limitadamente su *summa potestas* o *plenitudo potestatis* en el marco de la sociedad feudal estamental³. Con la consolidación de la estructura estatal en los siglos modernos, y en parte por las circunstancias contextuales en la convulsa vida europea del momento, se evidenciaron los límites de la monarquía, que la llevaron a superar, cuando hizo falta, por la vía de hecho, los compromisos existentes de raíz medieval. De estos límites, podríamos decir que los había de carácter interno y de carácter externo. Entre los límites de carácter interno podríamos considerar que había, en primer lugar, **los poderes y las autonomías municipales**; en segundo lugar, **la limitación del ejercicio del poder por parte de los estamentos** (o, a veces, sus intentos de limitación) y, en tercer lugar, el **parlamentarismo** (activo) como vía de comunicación y de participación política. Entre los límites de carácter externo estaba, por un lado, el **papel supranacional** que tenía (y reclamaba para él mismo) el imperio y, por el otro, el **papado**, a pesar de que no siempre contaban con el reconocimiento debido por parte de los reinos.



Portada de la edición de 1576 de la obra de Jean Bodin *Les six livres de la République*

Fuente: https://fr.wikisource.org/wiki/page:Bodin_-_Las_Six_Livres_de_la_République,_1576.djvu/13

⁽³⁾Ved el apartado «La recepción del *ius commune*» en el módulo «Lección II: La Europa medieval (s. IX-XV)».

Más allá de la construcción teórica de Bodin, en la cual no entraremos ahora con más detalle, hay que tener en cuenta el esfuerzo que hizo para encajar en la realidad heredada la nueva visión (de hecho, de sobreponerla) y cómo, por esta razón, por ejemplo, se ocupaba de (contemporizar dentro de su teoría) las asambleas estamentales y la república, junto con la nueva idea de soberanía. Con la visión de conjunto de su planteamiento y con la evolución posterior que tuvo desde el punto de vista político, constituyen lo que podríamos considerar afirmaciones circunstanciales que en ningún caso podrían suponer traba alguna al ejercicio del poder del monarca.

Llevado al ámbito del derecho, el ejemplo más claro se manifiesta en la capacidad creadora de normas, en la capacidad para legislar, que, consecuentemente con los planteamientos de Bodin, tendría que carecer de trabas, límites o controles. El afianzamiento de la soberanía presuponía la superioridad del poder de la monarquía por encima de todo el derecho establecido. Es por ello que cuando Bodin habla de los rasgos o marcas de la soberanía, menciona la capacidad del rey (él lo llama **príncipe**) para legislar sin concurso de nadie, sin que le haga falta el consentimiento de sus súbditos.

Fruto de una tradición y de una herencia, la monarquía no pudo desvincularse totalmente de la realidad, y es por esto que, de acuerdo con la concepción cristiana del mundo, el monarca solo estaba vinculado a la divinidad y a la razón, como, en estos aspectos concretos, ya lo había estado la monarquía en épocas anteriores⁴.

⁽⁴⁾Ved los apartados «Carlomagno y la restauración del Imperio» y «La sociedad feudal y el derecho alto-medieval» del módulo «Lección II: La Europa medieval (s. IX-XV)».

El cambio en la facultad de legislar se producía en el hecho de que, a diferencia de épocas anteriores, donde el monarca, según los territorios, estaba condicionado, vinculado, en virtud del pacto feudal, por las instituciones del reino y por la legislación, ahora, en la teorización de Bodin, se vería libre de todas estas limitaciones, y, así, no estaría vinculado ni a sus propias leyes, y podría legislar a voluntad, con completa libertad, creando derecho nuevo o modificando el derecho existente, sin intervención de sus naturales, ahora ya súbditos, los cuales se convertirían en simples destinatarios, simples receptores, de las normas; normas que ya solo dependerían de la voluntad del monarca, único titular de esta (nueva) manifestación de la soberanía.

2.6. Camino del absolutismo

Una manera de explicar la evolución de este periodo podría ser plantear una reflexión más amplia sobre la evolución y el carácter de la monarquía a partir de diferentes aproximaciones e interpretaciones radicalmente opuestas. Así, por un lado, está el planteamiento de los autores que se aproximan a ella y dan la primacía a un carácter triunfante y de progreso. Para hacerlo, se plantean que lo que era «actual» y «moderno» en aquel momento era precisamente esto,

Bodin y lo que implicaba, y que, por lo tanto, progresar significaba evolucionar hacia el autoritarismo y el absolutismo. Desde esta óptica, automáticamente se colocaría todo lo que no evolucionara en esta dirección, en una posición retrógrada, contraria a la monarquía y, por tanto, al progreso entendido de este modo. Desde este planteamiento, la monarquía francesa sería la pionera, y la monarquía castellana estaría en el camino del progreso, mientras que los estamentos del Reino de Aragón o del Principado de Cataluña, no.

El otro planteamiento es el de los autores que parten de otros términos y se centran en la correlación de fuerzas, el marco legal y de legitimaciones del momento. Así las cosas, que los estamentos de la Baja Edad Media o de la edad moderna, en un territorio como por ejemplo Aragón, Valencia o, sobre todo, Cataluña, argumentaran y reivindicaran que la monarquía estaba unida, no solamente por una tradición ancestral, sino también por una serie de compromisos jurídicos y políticos adquiridos por el monarca reinante y por todos sus antecesores, no supondría que fueran retrógrados. En la defensa de sus derechos y de sus reivindicaciones políticas se aferraban, desde el punto de vista jurídico, a lo que les daba fuerza y legitimación (los acuerdos, los privilegios, los pactos, la legislación aprobada por las instituciones del territorio, el juramento del monarca...). Difícilmente podría ser de otra forma, por la misma estructura matriz de la sociedad, una sociedad estamental de base feudal, origen de la misma monarquía (hecho que también se había compartido con otros territorios, como Castilla, pero que por la diferente evolución política y del papel de la monarquía, había dirigido a situaciones y soluciones diferentes).

Así, la entronización de un nuevo monarca era el acto solemne por el cual pasaba a ser tenido por monarca (rey, conde, etc.) y señor natural del territorio. Para que esto pudiera ser, hacía falta que el nuevo monarca jurara la legislación hasta entonces aprobada por sus predecesores, que la cumpliría y observaría, y que la haría cumplir y respetar a sus oficiales. Después, sus naturales, representados por los miembros de los estamentos reunidos en la asamblea parlamentaria, le juraban fidelidad y lo reconocían como señor natural. Se sellaba así de manera formal y solemne el pacto de fidelidad y naturaleza que los vincularía en adelante. Con la opción elegida, le recordaban doblemente que se trataba de legislación vigente y aplicable que, como rey, era preciso que respetara. El recordatorio entraba dentro de los tira y afloja propios de las relaciones políticas del momento y no era, ni mucho menos, gratuito, puesto que tanto el monarca como sus oficiales, al gobernar, tendían a no tenerlo presente (o, mejor dicho, a olvidarlo) y a salirse por la tangente, es decir, a actuar en función de sus intereses o necesidades inmediatas, negligiendo los regímenes jurídicos propios de los miembros de los diversos estamentos de los distintos territorios de los cuales los reyes eran titulares. Una actuación equivalente se producía cada vez que se concluía una reunión de cortes, en la aprobación y sanción de la legislación de las asambleas estamentales. En virtud de este acto de sanción y promulgación de la legislación elaborada en la reunión, se actualizaba el compromiso del monarca del mismo modo y en el mismo momento

que se actualizaba el ordenamiento jurídico con la nueva legislación. Los dos aspectos se sumaban así al compromiso inicial de la entronización y reforzaban la legalidad de las actuaciones y el vínculo entre el rey y sus naturales.

Europa a comienzos del siglo XVII



Fuente: adaptación propia a partir de http://www.euratlas.net/history/europe/1600/1600_Northwest.html i http://www.euratlas.net/history/europe/1600/1600_Southwest.html

Esta interpretación permite entender y explicar, por ejemplo, que en el siglo XVII, ante las pretensiones del conde-duque de Olivares de formar una **unión de armas** (ya citada) con soldados procedentes de los diversos territorios (reinos) hispánicos para ir a combatir a Flandes, la respuesta de los estamentos catalanes fuera invocar la legislación que el monarca, Felipe IV de Castilla y III de Cataluña y Aragón (1621-1665), había jurado cumplir y hacer cumplir al ser entronizado, y, en concreto, invocaran el *usatge Princeps namque*, que establecía que los catalanes solo tenían que armar un ejército cuando el territorio del Principado se viera amenazado, y no era el caso. Sin entrar más en la complejidad de la situación, se trataba de ejemplificar el aspecto de las argumentaciones y de las legitimaciones sobre la base de una cuestión jurídica basada en el compromiso adquirido. El choque de maneras de proceder, con la monarquía por un lado, y los estamentos por el otro, tardaría más o menos según los territorios, pero se acabaría produciendo.

Es, pues, desde esta perspectiva de evolución de la monarquía que –es una forma de verlo– se puede considerar el tránsito de las monarquías cristianas medievales hacia el absolutismo como una evolución que acabará siendo a la baja.

Dicho con otras palabras, la parte final de la evolución de la monarquía cristiana medieval, una monarquía fortalecida en la edad moderna en el contexto internacional de las grandes potencias, con el salto cualitativo que supuso la teorización de la soberanía de Bodin, y el inicio de la escalada hacia el absolutismo regio.

Una última fase, de declive, de la institución monárquica, de un modelo en descomposición, que se fue languideciendo, al compás de los tiempos, hasta que desapareció el Antiguo Régimen con el estallido de la revolución liberal burguesa⁵.

⁽⁵⁾Ved el módulo «Lección IV: El derecho contemporáneo».

Poner en práctica los postulados de Bodin, donde la titularidad de la soberanía estaba exclusivamente en manos del monarca, con una pérdida de papel real de las asambleas estamentales, con la preeminencia de la corte real como centro de la gestión política y actuando también como filtro de poder para acceder al monarca, eran algunos de los elementos que caracterizaban esta nueva época que desembocó en la monarquía absoluta, el absolutismo, forma de gobierno propia del Antiguo Régimen.

La monarquía recibe el nombre de **absoluta** porque tiene y acumula todos los poderes del reino; el monarca ejerce un **poder absoluto** sobre sus súbditos, un poder discrecional y sin limitaciones.

En la monarquía absoluta todo pasa (cuando menos, en teoría) por las manos del monarca (o de sus oficiales), como culminación del proceso de centralización de los estados en manos de la monarquía. Sin otros vínculos que los apuntados, no hay ninguna institución que pueda controlar la monarquía, y, en caso de que se convocara alguna asamblea, únicamente tendría carácter consultivo.

El **absolutismo**, como forma de gobierno, se fue formando en diversos territorios de Europa desde finales del siglo XV, especialmente en el siglo XVI (por ejemplo, en territorio francés), se extendió en el siglo XVII, si bien también en este ámbito la evolución inglesa fue diferente de la del continente, y, después de la «Revolución gloriosa» de 1688 con que se derrocó a Jaime II y se entronizó a Guillermo de Orange, con la aprobación de la *Bill of rights* (o declaración de derechos) de 1689 y las limitaciones a la actuación de la monarquía y el refuerzo de los derechos de los súbditos y de la figura del parlamento que establecía, se impidió cualquier evolución hacia posiciones absolutistas en las Islas británicas.

El absolutismo perduró, en general, hasta el siglo XVIII, para acabar desapareciendo con las revoluciones liberales (salvo Rusia, en el siglo XIX), por causas suficientemente conocidas⁶.



Bill of Rights, 1689

Fuente: <http://www.bl.uk/onlinegallery/takingliberties/staritems/510billofrightspic.html>

⁽⁶⁾ Los aspectos político-jurídicos de las causas se tratan en los apartados «Revolución liberal y derecho» y «Un nuevo orden político-jurídico» del módulo «Lección IV: El derecho contemporáneo».

Europa en el siglo XVIII



Fuente: <https://colomabea.files.wordpress.com/2014/09/1-europa-xviii.jpg>

El omnímodo poder del monarca, la centralización, la exacción de impuestos, un gran número de oficiales en el aparato burocrático, un ejército permanente, la supeditación de la Iglesia, son algunos de los elementos definidores de esta forma de gobierno. El caso francés es el exponente más claro de ello, mientras que para encontrarla en la península ibérica se deberá esperar hasta el siglo XVIII, después de la Guerra de Sucesión y de los Decretos de nueva planta.

En Francia, por ejemplo, Luis XIII (1610-1643) reforzó la monarquía, y con Richelieu en el gobierno desarrolló el absolutismo monárquico al compás de las guerras. Su hijo, Luis XIV (1643-1715), conocido como «el rey sol», con un régimen absolutista y centralizado (que se convirtió en arquetípico), construyó Versalles, símbolo de su poder, con todo lo que ello comportaba (gastos, dimensiones de la corte del rey, y, desde 1682, palacio, separado de la ciudad de París, desde donde gobernar a los súbditos).

Corte del rey en Versalles



Fuente: <http://maisonarts.forumgratuit.org/t29p15-metiers-d-autrefois>

En un contexto de numerosos conflictos bélicos, de aumento de la presión fiscal y de crecimiento territorial de Francia, prohibió los ejércitos privados, reorganizó el ejército, que convirtió en real, permanente y potente, a la vez que creó una flota de barcos. Preocupado por defender el territorio de los enemigos externos, encargó fortificar las fronteras.

Defensa del reino

Luis XIV encargó al ingeniero Vauban que revisara y reforzara las principales fortificaciones, especialmente las fronterizas y claves para poder defender el reino. En relación con las tierras fronterizas con los territorios hispánicos, hizo fortificar varios fuertes en el área de los Pirineos (en Le Perthus, en Vilafranca de Conflent) y de Perpiñán (en Salses), entre otros.

El reinado de Luis XIV (1642-1715) fue el prototípico de un monarca absoluto de la época. El ejercicio de poder se hacía de manera indiscriminada por parte del rey. Prácticamente no había posibilidad de distinguir las facultades que el monarca ejercía, más allá del aspecto funcional (hacer leyes, administrar justicia, recaudar impuestos, gobernar, conceder privilegios, etc.), ya que por

definición todas las manifestaciones de poder por parte del monarca formaban parte, inseparablemente, del todo que era la soberanía única del monarca absoluto.

Este hecho, con las consecuencias negativas que tuvo por los abusos que se cometieron, en un contexto de falta de garantías en comparación con la monarquía cristiana medieval, generó, junto con otros factores concomitantes, una reacción clara por parte de los pensadores ilustrados, que se convertiría en uno de los postulados revolucionarios básicos del estado de derecho: **la separación o división de poderes**⁷.

⁽⁷⁾Ved el apartado «Un nuevo orden político-jurídico» del módulo «Lección IV: El derecho contemporáneo».

Con la Ilustración se evolucionó –sin perder los rasgos definidores del absolutismo– hacia una nueva situación que se describiría posteriormente como el **despotismo ilustrado**. En esta deriva, con voluntad de reforma sobre la base de ideas ilustradas y de la razón como principio rector, el monarca reivindicaba el papel de servidor racional del estado, tratando de legitimar tanto las actuaciones que hacía (que no podrían ser despóticas) como de justificar su función sin tener que recurrir a la divinidad, en todos los ámbitos posibles de la sociedad (económico, agrícola, industrial...).

En cuanto al ámbito jurídico, será precisamente en este periodo cuando se empezarán a plantear y a ejecutar algunas nuevas maneras de hacer leyes, los **códigos** –fruto de la razón, del racionalismo–, que aparecerán, empezarán a desplazarse y cobrarán un sentido completamente distinto en los estados liberales burgueses, con el constitucionalismo⁸.

Voluntad de reforma del Despotismo ilustrado

Este cambio, caracterizado a menudo por la frase «todo para el pueblo, pero sin el pueblo», se produjo hacia la segunda mitad del siglo XVIII en algunos territorios de la Europa central y occidental, por ejemplo, con monarcas como Pedro el Grande, zar de Rusia (1682-1725), Federico II de Prusia (1740-1786), José II, emperador austriaco (1765-1790), o Catalina II, zarina de Rusia (1762-1796).

⁽⁸⁾Ved el apartado «Constitucionalismo» del módulo «Lección IV: El derecho contemporáneo».

3. La consolidación del poder regio, el derecho general y la prelación de fuentes

3.1. Poder regio, derecho del rey y derecho del reino

El afianzamiento del poder de los monarcas empezó a producirse en los diversos territorios europeos en la edad media con resultados dilatados a lo largo de la edad moderna, en parte compartidos (una tendencia a la consolidación del poder del rey), en parte divergentes (la forma y el calendario como se acabó produciendo).

Como sabemos por el caso de los reinos hispánicos medievales, este proceso inicialmente común a las monarquías acabó teniendo desarrollos y estructuraciones diferentes, en función de las relaciones y correlaciones que se establecían entre los monarcas y sus naturales. Sobre la base medieval que arrancaba de la herencia altomedieval con una presencia relevante de los ordenamientos señorial y municipal, ante el llamado **derecho del rey**, que se empezaba a manifestar, empezó a tomar cuerpo, al ritmo que se iban consolidando las instituciones parlamentarias representativas, la diversificación formal de la legislación.

Así, después de la recepción de los principios del *ius commune*, los monarcas bajomedievales y modernos ejercieron su capacidad normativa (o potestad legislativa) propia o privativa haciendo y promulgando su legislación en sus territorios (por ejemplo, en el caso de los territorios hispánicos, un ejemplo de disposición privativa del monarca podrían ser las pragmáticas sanciones, o los privilegios).

Correlativamente, a medida que se fueron implantando y generalizando, convocadas por el rey, las asambleas parlamentarias con capacidad para participar en la elaboración de la legislación, fue apareciendo una nueva realidad normativa, fruto de la colaboración prestada por los estamentos en la elaboración de la legislación, del que sería llamado el **derecho del reino** (y aquí entraría toda la legislación hecha en la asamblea parlamentaria de que se tratara).

El derecho del reino se manifestaba en un contexto donde los territorios tenían definida su personalidad jurídica de manera clara; esto permitía al monarca, con el concurso de los representantes del reino, cuando se celebraba reunión de la asamblea, hacer leyes que permitieran a su pueblo vivir con paz y con justicia, y, por tanto, cumplir con su función real; a la vez, permitía también ir creando una serie de normas que se extendían por todo su territorio y que se fueron regulando y homogeneizando desde el punto de vista jurídico (uni-

formándolo), al mismo tiempo que las instituciones encargadas de llevar adelante la administración del territorio fueron evolucionando técnicamente en este mundo cada vez más complejo.

La existencia del derecho del reino fruto de la colaboración legislativa entre el rey y la asamblea parlamentaria permitió contraponer este concepto al ya existente del derecho del rey, y que en determinados territorios se plantearan dudas sobre la relación que había entre ellos.

Independientemente del recorrido de esta cuestión concreta, el punto final de llegada fue la implantación del **absolutismo regio**, y, por tanto, la generalización forzosa de la conciencia de que el derecho y las leyes, en manos exclusivamente de la soberanía de la cual era único titular el monarca absoluto, provenía solo de él.

3.2. Derecho general territorial y órdenes de prelación de fuentes

3.2.1. Derecho general territorial

El **mundo moderno**, con su origen en la sociedad estamental medieval, donde los brazos eclesiástico y militar eran estamentos privilegiados (y disfrutaban, por ejemplo, de la exención de pagar impuestos, a la vez que tenían tribunales especiales para ser juzgados), era un mundo que seguía siendo profundamente desigual, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico y también jurídico. El derecho así lo reflejaba.

Y esto era así porque el régimen jurídico de las personas iba unido a su condición (tanto personal como del estamento al cual pertenecían) y, de hecho, dependía de ella. Dicho con otras palabras, una persona física (o, en su caso, una persona jurídica) tenía el régimen jurídico común del estamento al cual pertenecía, más su régimen jurídico propio, personal, individual, que la distinguía en relación con el conjunto de la sociedad donde vivía. Así pues, los miembros de un mismo estamento tendrían todos unos mismos privilegios (la parte común que compartirían), pero cada uno de los miembros, además de estos privilegios estamentales compartidos, tendría, en su caso, sus propios privilegios personales. Si se trataba de una persona física, por ejemplo, un eclesiástico o un noble, si eran de los privilegiados, o un ciudadano de una determinada localidad, si era del estamento real. En la misma línea, pero en otro nivel, si se trataba de una persona jurídica, como por ejemplo una institución eclesiástica (en el caso de los privilegiados) o una villa o ciudad del estamento real.

La singularización del régimen jurídico de las personas se materializaba a partir de los **privilegios**.

Privilegio

La etimología del término **privilegio** proviene del latín, *privus* y *lex*, es decir, 'ley particular, especial, singular', o sea, ley o acuerdo privado, entre particulares.

Conviene tener presente que, en el contexto de las asambleas parlamentarias, de acuerdo con la construcción de los juristas, el monarca no podía pedir dinero a cambio de la legislación general que daba a su territorio. Y no lo podía hacer porque estaba obligado a ello en virtud de su cargo. En cambio, precisamente a partir de esta consideración, los juristas argumentaban que los privilegios que otorgaba el monarca eran «ley entre particulares» y, por tanto, como tales podían ser objeto de transacción. En el caso de los privilegios era lícito que el monarca, a cambio del privilegio que concedía, recibiera una compensación económica del beneficiario. Así pues, los privilegios se podían comprar al monarca y el monarca los podía vender, pero no se admitía que esto mismo se pudiera hacer con la legislación.

Los privilegios, pues, eran concesiones de los monarcas a sus naturales, en algún caso quizás por vía de gracia, pero, en general, eran concedidos a cambio de un precio. En términos generales, el beneficiario –que podía ser tanto una persona física como una persona jurídica– lo compraba.

Así pues, dependiendo del tipo de privilegio de que se tratara, el sujeto beneficiario disfrutaba de una exención ante una determinada ley, norma o regulación general.

Por poner solo dos ejemplos, podemos hablar del privilegio de que una localidad tuviera feria y del privilegio llamado **de cobertura**. En relación con el primero, desde el punto de vista de la municipalidad, una villa era privilegiada si había podido disponer de suficiente dinero para comprar un privilegio al monarca para tener, por ejemplo, feria o mercado cada cierto tiempo. En cuanto al llamado **privilegio de cobertura**, se trataba del privilegio que permitía a quien disfrutaba de él poder permanecer con la cabeza cubierta ante el monarca, no tenerse que descubrir, no tener que quitarse el sombrero, ante el rey, puesto que, salvo los grandes de España, por principio, la regla general era que todo el mundo tenía que ir con la cabeza descubierta ante el rey (es decir, se tenían que quitar el sombrero delante de él). Los consejeros de Barcelona, en el convulso siglo XVII, argumentaban que disfrutaban de este privilegio, y asistieron a un acto ante el monarca con el sombrero puesto, hecho que suscitó un incidente protocolario con los oficiales reales, en un momento políticamente delicado y en un tiempo en que las cuestiones formales y protocolarias se interpretaban como el fiel reflejo de la jerarquía social y política y de la correlación de fuerzas existente entre las partes implicadas (probablemente porque tenían en cuenta que, en un momento dado, todo podía incidir en la posición que se tenía de cara a cualquier posible negociación).

Tanto desde la óptica de la tradición romano-teodosiana, como desde la óptica de la tradición romano-justiniana, la legislación era fruto de la actividad del monarca, y una muestra evidente de la centralización de la nueva estructura estatal. En Francia, por ejemplo, a partir del siglo XVI se fue expandiendo y reforzando la legislación real, que se convirtió en la fuente principal de derecho a la vez que un símbolo del afianzamiento del estado. En Inglaterra, la relación entre monarquía y Parlamento fue fluctuante; descontados los casos extremos, se fue conformando el principio de que el rey era una figura importante, pero que la figura suprema era el rey con el Parlamento. En la Península, la línea de afianzamiento del poder real que se manifestó e implantó en Castilla desde la Baja Edad Media, en el resto de territorios no se pudo imponer con la misma rapidez. Los intentos por conseguirlo marcaron la evolución de las relaciones y los conflictos de estos territorios con el monarca durante la edad moderna.

Además de las normas de origen consuetudinario que pudiera haber en un territorio determinado, la legislación podía ser, pues, obra del monarca, en general, o bien del monarca con la participación de otras instancias, según los casos. Así, la legislación aprobada por el monarca, o por el monarca con la participación de sus naturales en el marco de las asambleas parlamentarias de los diferentes territorios, cada vez más devenía la legislación general del territorio y -inmunidades jurisdiccionales aparte-, se aplicaba a todos sus naturales.

En la medida en que la actuación decidida de la monarquía (o mejor dicho, tan decidida como las circunstancias se lo permitían) tendía a irse imponiendo a los estamentos de origen medieval desde la Baja Edad Media y a situarse por encima de las esferas del derecho municipal y del derecho señorial⁹ – que continuaban siendo inmunidades jurisdiccionales con un régimen jurídico propio –, el monarca fue consolidando su papel al frente de sus naturales, e impulsando la legislación (solo suya, o suya con la participación de los estamentos) con validez general territorial. Paralelamente, se fue entrando en una dinámica de enfrentamientos políticos entre el rey y los estamentos que a menudo se escenificaba, pero no únicamente, con ocasión de los encuentros para celebrar las reuniones señaladas de las asambleas parlamentarias.

Ante la progresión de la monarquía, ya hemos visto que los estamentos optaron por invocar constantemente sus privilegios (de raíz medieval), que eran las normas que fundamentaban jurídicamente su situación privilegiada. Desde el punto de vista legislativo, algunos principios originarios del derecho romano imperial, y provenientes de la recepción del *ius commune*, se fueron desarrollando y difundiendo de nuevo de la mano de los juristas formados en los estudios generales, porque apoyaban las aspiraciones de la monarquía. El conocido principio de derecho imperial romano *Quod principi placuit legis habet vigorem* servía de argumento para fundamentar la regalía de la legislación y la exclusividad de su ejercicio por parte del monarca. Por el contrario, los estamentos argüían el principio canónico *Quod omnes tangit, ab omnibus approbare debet* y justificaban, de este modo, la necesidad de que determinadas decisio-

Tradición romano-teodosiana y romano-justiniana

Cuando hablamos de tradición romano-teodosiana hacemos referencia a la tradición que llega vía Código teodosiano – sin llegar a la recepción del *ius commune* –, con el *Liber iudiciorum* incluido, es decir, la que se ha producido en los territorios de la península ibérica con el transcurso del tiempo. Cuando hablamos de la tradición romano-justiniana, en cambio, hacemos referencia a la tradición que llega por la recepción del *ius commune*, es decir, principalmente, el derecho romano justiniano, el *corpus iuris* boloñés, o sea, la que llega de fuera de la península ibérica vía Bolonia, con la recepción del *ius commune*.

⁽⁹⁾ Véase el apartado «La recepción del *ius commune*» del módulo «Lección II: La Europa medieval (s. IX-XV)».

Quod principi placuit legis habet vigorem

La máxima o principio *Quod principi placuit legis habet vigorem* se puede traducir como 'aquello que place al príncipe, tiene fuerza de ley'. Con origen en el derecho imperial y desarrollada por los juristas al servicio del emperador romano, en la edad media se usó para fundamentar la capacidad legislativa del monarca.

nes relevantes (incluida la legislación) no fueran resultado solo de la voluntad del monarca y de sus oficiales, y que se tuviera que tener en cuenta, de alguna manera, el parecer y la participación estamental antes de decidir, si bien esta posición se iría viendo debilitada por la dinámica de los hechos cuanto más avanzaba la edad moderna, más se afianzaba la posición del monarca y más difusión tenían las teorías de Bodin y se iban llevando a la práctica.

Las **soluciones concretas** según los territorios eran diferentes, como también la terminología con que se designaban las instituciones o las mismas disposiciones aprobadas.

Quod omnes tangit, ab omnibus approbare debet

La máxima o principio canónico *Quod omnes tangit, ab omnibus approbare debet* se puede traducir como ‘aquello que a todos afecta, por todos tiene que ser decidido’. De origen romano para un contexto completamente diferente, se desarrolló en la edad media por los juristas canonistas en el marco de las teorías conciliares sobre el consentimiento en los siglos XIV-XV.

En un territorio como el reino de Castilla el poder del monarca se había establecido y fundamentado ampliamente desde la Baja Edad Media sin encontrar demasiada oposición en los estamentos, hasta el punto de que la legislación propia del monarca (las **pragmáticas**) coexistía, en el mismo nivel, con la del monarca en la asamblea estamental (**ley, ordenamiento de cortes**). En cambio, en Cataluña, el monarca había aceptado desde las cortes de Barcelona de 1283-1284 el no hacer disposiciones generales (las **constituciones de cortes** y, más tarde también, por equiparación, los **capítulos de cortes**) sin la participación y el consentimiento –en determinadas condiciones– de los estamentos convocados a la reunión.

Como hemos dicho, variaba la terminología con que se designaban las instituciones y la legislación general. Por lo que respecta a la institución parlamentaria, los nombres eran **cortes** en Aragón, Castilla, Navarra o Portugal, **cort general** o **corts** en Cataluña, **corts** en Valencia, **parliament** en las tierras inglesas, **dieta** en los territorios alemanes y húngaros, y **états** en los franceses. En relación con la denominación de la legislación general, por ejemplo, había **fueros** en Aragón, **leyes y ordenamientos de cortes** en Castilla, **leyes** en Navarra, **constitutions y capítols de cort** en Cataluña, **furs** en Valencia; en las tierras inglesas, **ordinances, acts y statutes** y, en las francesas, **ordonnances y édits**.

Esta realidad de origen medieval singularizada en diferentes instituciones (es decir, diferentes tipos de asambleas parlamentarias) no era otra cosa, a la hora de formarse las instituciones parlamentarias denominadas representativas, que la concreción a las circunstancias del mundo bajomedieval y moderno de la evolución de las instituciones visigodas y feudales altomedievales (curia regia, curia plena, curia ordinaria, curia extraordinaria), sobre todo teniendo en cuenta el pacto de vasallaje y los deberes de *auxilium et consilium* –es decir, de ayuda y de consejo– inherentes al mismo, que los vasallos tenían hacia su señor.

Aquí se debe hacer una precisión importante: una manera extendida de referirse a las asambleas parlamentarias de los diferentes territorios es designarlas genéricamente como **instituciones representativas**. Hay que entender este

sintagma nominal solo en el sentido que tiene. Aplicado a asambleas parlamentarias del mundo medieval y moderno –excluidas las monarquías absolutas–, **representativo** quiere decir tan solo esto, ‘que representa’, y de hecho, las asambleas **representaban** a la totalidad de los naturales del monarca, a todo el territorio (reino, principado...), en aquel momento. Esto era así porque, según los parámetros de la época, la asamblea parlamentaria representaba en aquel momento a los presentes y a los ausentes, a la totalidad de los naturales del monarca, a todo el reino. La representación se entendía hecha incluso aunque no asistieran a ella personalmente, tanto si habían sido convocados como si no tenían derecho a asistir porque, por ejemplo, acudiendo un conde o un obispo –el titular de la jurisdicción del condado o del obispado– era como si ya acudiera todo el condado o todo el obispado; acudiendo el titular era como si hubieran acudido todos sus vasallos. Así las cosas, **representativo** no tendrá connotaciones, llamémoslas «democráticas», en el sentido actual del término, hasta después de la Revolución Francesa, e incluso, aun dependiendo del texto constitucional y de la legislación electoral de que se trate en cada momento y territorio concreto.

Las primeras noticias que se puede encontrar para los varios territorios con asambleas parlamentarias consideradas representativas en el sentido medieval del término, y teniendo en cuenta que están determinadas en función de la fecha de entrada a la institución de los representantes de las ciudades y villas reales, oscilan entre el final del siglo XII y el siglo XIV.

El funcionamiento estaba basado sobre todo en la práctica, en la costumbre, en el precedente. Habitualmente, era el monarca quien convocaba a los miembros de la asamblea para tener una reunión y tratar los temas de interés general. También pedía colaboración económica a sus naturales, legislabá y reparaba las quejas que se le presentaban por abusos y extralimitaciones suyas y de sus oficiales. Estas quejas en algunos territorios recibían el nombre de *greuges* (en Cataluña, en Valencia y aun en Aragón) o, en latín, *gravamina* (en los lugares indicados y también en otros territorios europeos, como Hungría, por ejemplo). En Castilla las quejas de este tipo se planteaban en los **cuadernos de peticiones**, en Navarra en los de **agravios**, en los territorios franceses en los *cahiers de doléances*, y en Inglaterra eran presentadas como *petitions* o *grievances*.

La celebración de la asamblea parlamentaria, cuando no había una crisis política abierta o un conflicto bélico, era una ocasión que permitía tener y renovar, de manera recíproca, el contacto entre el monarca –como titular del poder político y señor natural del territorio y su gente– y sus naturales –con los cuales tenía vínculos y obligaciones– y, en su caso, restablecer el equilibrio en sus relaciones.

Primeras fechas

Las primeras fechas son a finales del siglo XII para el Reino de León (1188); el siglo XIII para Cataluña (1218), Reino de Aragón (1247), Reino de Castilla (1250), Reino de Valencia (1261), más la dieta alemana y el Parlamento inglés también del siglo XIII, y, ya en el siglo XIV, los casos del Reino de Navarra y de los *états* franceses.

Petition of right

En otro contexto institucional y territorial, el Parlamento inglés en 1628, entre otras medidas, aprobó el *Petition of right* en virtud del cual, el Parlamento, con las dos cámaras actuando conjuntamente, manifestó su voluntad de no aceptar ningún impuesto que no hubiera sido votado por el Parlamento. Por su trascendencia, se lo considera un documento clave de la historia constitucional inglesa, como la *Magna carta* de 1215, o el *Bill of rights* de 1689.

Petition of Right, 1628



Fuente: <http://www.bl.uk/collection-items/the-petition-of-right>

La manifestación más clara del deber de *auxilium* que los naturales debían al monarca se manifestaba en la contribución económica con carácter extraordinario que se concedía al rey con ocasión de la celebración de las cortes. Ciñéndonos a la península ibérica, la dinámica variaba de territorio a territorio, también en este aspecto. En Castilla se hablaba de **servicio**, y en Cataluña de **proferta**, de **oferta**, de **subsidi** o de **servei**. Con estos términos se designaba el importe –a menudo considerable– de dinero que, voluntaria y liberalmente, los convocados a la asamblea parlamentaria decidían otorgar al monarca con carácter excepcional, extraordinario, después de haberle escuchado y habiendo debatido y negociado al respecto. La denominación no era gratuita ni irrelevante. Evitaba cualquier referencia a una periodicidad establecida o a una imposición aceptada, ni que fuese de forma siquiera implícita, para que nunca se pudiera argumentar que había sido aceptado como una imposición (un impuesto) el hecho en sí, ni por la vía formal ni por la vía del precedente consumado. Con los términos empleados se garantizaba, al menos formalmente, que no se podía traspasar el terreno de la mera liberalidad, hecho que dejaba las manos libres a los estamentos en este ámbito para negociar en las cortes, con los otros estamentos y con los oficiales regios.

En este contexto institucional, para restablecer el equilibrio se contaba con varios mecanismos, los más efectivos y evidentes de los cuales eran, a menudo, una **buena legislación** (que permitía a los convocados participar en el proceso y cumplir su deber de *consilium* con el rey) y también la posibilidad de **reparar**

los abusos cometidos. Correlativamente, cuando la maquinaria institucional funcionaba sin fricciones, se iba avanzado a buen ritmo y la concesión del donativo o servicio se esperaba que fuera rápida y sustanciosa, lo que no siempre sucedía.

Con la **legislación**, en especial con la elaborada en el marco de una asamblea estamental, se podía satisfacer el objetivo de administrar justicia legislando, porque, con leyes buenas y justas, los naturales del monarca podrían vivir en paz y con justicia, que era una de las obligaciones que el monarca tenía, por el hecho de ser rey, hacia su pueblo.

Esta afirmación, realizada a todos los efectos y para la mayoría de territorios europeos durante el periodo, debería relativizarse en aquellos territorios en que el monarca no contaba con la plena intervención de los estamentos, ni con su oposición en su caso. En el reino de Castilla, a partir de 1538, las **cortes** quedaron formadas solo por el estamento real, ya que las clases privilegiadas (los estamentos eclesiástico y militar) dejaron de asistir a ellas. Desde entonces, las reuniones de las **cortes castellanas** se hicieron solo con la asistencia del estamento popular (los representantes de las ciudades), que era el que satisfacía la contribución económica al rey, prácticamente sin plantear oposición, en comparación con otras asambleas parlamentarias de otros territorios peninsulares.

El otro mecanismo que permitía volver a equilibrar las relaciones era la **reparación de los abusos cometidos** (*gravamina*, agravios, quejas, *greuges*, *doléances*, *petitions...*, según los territorios). Se solía llevar a cabo en el marco de la celebración de una asamblea parlamentaria escogiendo una comisión paritaria por parte del rey y de los estamentos nombrada *ad hoc* por el monarca, con una delegación específica de poder. Los afectados presentaban las reclamaciones y correspondía a la comisión instruir el procedimiento. Era habitual que la instrucción se alargara más allá de la asamblea parlamentaria y así se preveía. Acabada la instrucción, los jueces dictaban una resolución (en Cataluña, *sentència de greuges*).

La idea de base era simple: nadie estaba obligado a soportar ninguna carga que no estuviera determinada en una ley.

Cuando esto sucedía a alguien o había abusos y extralimitaciones, entonces, se podía presentar la reclamación, que mayoritariamente, en la edad moderna, era reconvertida en un montante económico para compensar la situación que se había tenido que soportar sin estar obligado a ello.

La duración de las reuniones de las asambleas parlamentarias bajomedievales y modernas variaba según el territorio y el momento. El Parlamento inglés, por las características del país y de su gente, se reunía con relativa facilidad y por periodos de tiempo, en general, cortos, sobre todo a finales de la edad media, que podían ser de unas pocas semanas, y ocasionalmente algunos meses (y, en la edad moderna, excepcionalmente, años, como la reunión conocida como «The Long Parliament», que, con interrupciones duró de 1640 a 1660).

En los reinos peninsulares, las convocatorias de reunión durante la edad moderna se fueron alargando cada vez más dependiendo del territorio, y, a veces, por no decir a menudo, su duración era considerable, y se contaba por meses. En el siglo XVII no hubo ninguna reunión de cortes concluida; se había convocado una en 1626, que se prorrogó hasta 1632, año en que se retomó y, nuevamente con prorrogaciones, se dejó inacabada. En el siglo XVIII, antes del decreto de Nueva Planta, hubo dos: la de 1701-1702 con Felipe de Borbón, y la de 1705-1706 con Carlos de Austria, cada una de las cuales duró unos tres meses. Después del decreto de Nueva Planta ya no hubo más.

Convocatorias de reunión

Si vemos las reuniones de corte catalanas celebradas en la edad moderna, podremos constatar que durante el siglo XVI hubo en 1503, 1510, 1512, 1515, 1519-1520, 1528, 1533-1534, 1537, 1542, 1547, 1552-1553, 1563-1564, 1585, y 1599. La más corta duró un mes (1599) y la más larga, nueve meses (1519-1520).

Además de constatar que estos factores influían decisivamente en la manera de funcionar y en las dinámicas de las instituciones respectivas, proporcionan indicios del valor que podía tener en cada ocasión una reunión de la asamblea estamental. En los casos apuntados, indica que era una ocasión que no debía desaprovecharse para retomar las relaciones afectivas (en el ámbito político) entre el monarca y sus naturales, hasta en aquel momento condicionadas por el establecimiento de la corte del rey en Madrid y el **entourage** burocrático (hoy diríamos funcional) que rodeaba y también controlaba la figura del monarca.

En este contexto es fácil aproximarse a las crisis (bélicas o no) de los diversos territorios peninsulares de la edad moderna fijándose en este aspecto concreto: el alejamiento progresivo (y no solamente físico) entre el titular del poder político y sus naturales.

Cada territorio continuaba su evolución, y el monarca y sus oficiales tenían otros puntos de vista condicionados por la política y los intereses internacionales, las alianzas, sus posesiones (como en el caso de Carlos I con las posesiones de Flandes), en un mundo cambiante donde la tendencia (acompañada por la teorización de Bodin) sería ir igualando en el trato –a la baja– a los naturales de la monarquía.

Esta tendencia de igualación a la baja comportaría, inicialmente, por un lado, desdibujar las peculiaridades de cada uno de los regímenes jurídicos de los reinos afectados (en la medida en que eran limitaciones a la actuación libre del monarca), y en un segundo momento, una abolición de todo aquello que

dificultara el ejercicio del poder del rey en los ordenamientos jurídicos de dichos reinos. Por otro lado, comportaría una mejor situación de la monarquía e, indirectamente de sus partidarios.

La mejora de situación de la monarquía se concretaría, pues, en una mayor libertad para actuar, y, correlativamente, en una aspiración hacia una legislación que no debería tener en cuenta a los sujetos destinatarios de las normas.

Hay quien argumenta que la multiplicidad de regímenes jurídicos diferentes generaba problemas y conflictos a los monarcas (que se veían encorsetados por los ordenamientos de los diferentes territorios). Así las cosas, no es extraño que la igualación a la baja se hiciera hacia un patrón que fuera el de un ordenamiento jurídico donde la intervención del monarca fuese preeminente, y también el de los naturales que planteaban menos problemas y conflictos al rey. En el caso peninsular, pues, la tendencia sería a igualar los naturales de la monarquía de los reinos periféricos al patrón de Castilla, donde el monarca tenía más libertad de actuación y menos oposición.

Sea como fuere, e independientemente de las crisis políticas, el estado se fue consolidando y su relación con las otras instituciones también. La celebración de cortes a los catalanes, siempre que se acababan las cortes de manera natural, comportaba que el monarca prestaba el juramento de la legislación aprobada en esa asamblea, y, correlativamente, por parte de los tres estamentos, ellos daban su consentimiento. Con este formalismo no solamente se promulgaban las nuevas normas y se les daba publicidad, sino que también se renovaba, con matices, el compromiso de fidelidad entre el monarca y sus naturales, en el marco de la celebración de la asamblea estamental complementando el primer juramento de cada monarca al ser entronizado.

Una vez licenciada la asamblea, el monarca y su protonotario se llevaban los textos y después el protonotario los devolvía debidamente escritos y formalmente elaborados para que tuvieran validez: era el *quadern de cort* (**cuaderno de cortes**) original que, con la generalización de la imprenta, acabaría siendo estampado a cargo de la Diputación del General catalana.

3.2.2. Órdenes de prelación de fuentes

Desde los inicios de la Baja Edad Media, con la llegada del derecho de la recepción, de sus principios, de sus materiales y de los juristas formados en su tradición, se empezó a ver el derecho propio de los diversos territorios con los ojos, con las gafas del *ius commune*.

Ver el derecho propio con los ojos, con las gafas del *ius commune* quiere decir que los estudiantes que habían estado formados en la tradición del *ius commune* y que habían

Resistencias al rey

En otros territorios que el castellano, el monarca encontraba resistencias en las cortes por parte de los estamentos, en general, y también en situaciones concretas que desembocaron en crisis y conflictos; pensemos, por ejemplo, si nos ceñimos a los territorios de la Corona de Aragón, en las Germanías de Valencia hacia 1520, en la ejecución del *Justicia mayor* de Aragón en 1592, o en la Guerra de los Segadores en 1640 en Cataluña.



aprendido el estudio y el manejo de las fuentes de derecho romano y canónico desde el punto de vista técnico, aplicaban todos los instrumentos de la profesión y la manera de razonar adquiridos en las leyes de los territorios de origen, y, así, empezaban a «tratar científicamente» la legislación propia, con los consiguientes progresos técnicos que ello supuso.

Primero técnicamente, pero después, enseguida se debieron de empezar a simultanear, en la práctica, elementos de los derechos propios con interpretaciones y soluciones propias del *ius commune*. Que el derecho propio fuera un derecho «vivo», creado y susceptible de ser modificado si hacía falta, y que el *ius commune* no lo pudiera ser, permitió que en determinados territorios, como por ejemplo en el Principado de Cataluña, se pudiera ir legislando, sobre la base de los planteamientos del *ius commune*, pero concretando en el derecho propio, a medida que se necesitaban las soluciones peculiares que en el territorio en cuestión se decidió adoptar sobre una determinada cuestión jurídica.

Por un lado, la legislación propia de cada reino, con sus soluciones particulares, y por el otro, la llegada del derecho de la recepción, hicieron que se tuviera que fijar y establecer jurídicamente la relación que existía en cada territorio entre el ordenamiento jurídico propio y el ordenamiento jurídico del *ius commune*, fruto de la recepción. La manera de fijar jurídicamente la relación entre los dos ordenamientos, con calendarios y soluciones diferentes en cada territorio, fue mediante la elaboración de una disposición de carácter general (**ley de cortes** en Castilla, **constitució** o **capítol de cort** en Cataluña, etc.). Dicha disposición conformaba un tipo concreto de las mismas en función del contenido. Para referirnos a ellas lo hacemos como **órdenes de prelación de fuentes**.

Los **órdenes de prelación de fuentes**¹⁰ son normas que determinan, que establecen, cuáles son las fuentes normativas válidas aplicables en un determinado territorio y fijan el orden, la prelación, que debe seguirse, para resolver un litigio en caso de **laguna legal**.

Con este tipo de disposiciones se homogeneizaba el ordenamiento, se armonizaba su aplicación, se aclaraba el funcionamiento del propio ordenamiento y la relación que había entre el ordenamiento jurídico propio y los demás, y se fijaba por adelantado el orden a seguir para resolver el litigio en caso de laguna. Se conseguía tener así, a partir de la promulgación de la norma, un criterio previo para todas las situaciones, en su caso, que garantizaba el mismo procedimiento de aplicación en todo el territorio.

Técnicamente, era necesario que la disposición estableciera explícitamente cuál era la norma o el ordenamiento aplicable «en caso de que faltara» la regulación en el ordenamiento vigente. Como históricamente había habido en la mayoría de territorios diversos ordenamientos o normas que habían tenido vigencia previamente, los órdenes de prelación seleccionaban el camino que debía seguirse para resolver el litigio. Y lo solían hacer desde un punto de vista lógico jurídica e históricamente, combinando los criterios temporales y de

Órdenes de prelación de fuentes

Los **órdenes de prelación de fuentes** fijan la relación entre el llamado **derecho principal** (el vigente en un determinado territorio) y los llamados **derechos supletorios** (aquellos a los que hay que acudir para buscar la regulación que no se encuentra en el ordenamiento principal, que pueden ser otros ordenamientos, u ordenamientos que habían estado en vigor al mismo territorio en otras épocas).

⁽¹⁰⁾ Aquí trataremos de los órdenes de prelación de fuentes del derecho general territorial, si bien debemos tener presente que también se encuentran, por ejemplo, con las mismas características técnicas, en el derecho municipal.

Laguna legal

Se denomina **laguna legal** a la situación en que no se encuentra, en la norma aplicable, la regulación del caso que se tiene que resolver. Una manera de evitar que hubiera dudas sobre qué otro ordenamiento o norma podía regularlo y si se tenía que acudir al mismo, era elaborar un orden de prelación de fuentes que lo previera.

amplitud de regulación. Dicho con otras palabras, solían recurrir primero a los ordenamientos más próximos en el tiempo, y a los que tenían una regulación no tan amplia como el supletorio siguiente. Se conseguía así acudir a un ordenamiento supletorio más conocido por el juez (por la proximidad temporal), y con más posibilidades de encontrar la solución cada vez que se pasara al supletorio siguiente, que contendría una regulación más amplia que el precedente.

Los órdenes de prelación de fuentes sirvieron también para evitar que quedara a criterio del juez la decisión de elegir a qué ordenamiento de los posibles supletorios se podía acudir para resolver el caso, o que decidiera hacerlo sobre la base de un criterio estrictamente personal.

En algunos casos, como Cataluña en 1599, se marcó el camino del juez para resolver los litigios en caso de laguna legal empezando por el derecho vigente y acabando con los ordenamientos del *ius commune* (canónico y romano) y la doctrina de los doctores en materia de equidad, para tratar de constreñir al máximo la libertad de decisión del juzgador, aunque sin llegar a cerrar el círculo.

En otros casos, se cerró el círculo, como Castilla en 1348 y 1505, en que se empezó con las leyes del rey y se acabó con la consulta al monarca, que decidiría el caso (como juez supremo del territorio) y decidiría si modificaba las leyes (como legislador) para conjurar futuras situaciones similares.

La preocupación de los monarcas, dado que la justicia se administraba en nombre suyo, fue la de fijar mecanismos para homogeneizar la tarea de los jueces reales y, a la vez que marcaban el camino a seguir ante las lagunas legales, les limitaban la posibilidad de razonamiento libre y, así, limitaban el riesgo de que la resolución del caso pudiera ser diferente o arbitraria.

Otro aspecto de los órdenes de prelación tiene que ver con la relación que tienen con las compilaciones o recopilaciones de derecho general. Así, hay una estrecha relación entre los órdenes de prelación de fuentes de un determinado territorio y el derecho que se recopila en ese territorio.

Aplicación del derecho

Recordemos que la idea de la aplicación del derecho tal como lo entendemos actualmente es relativamente nueva, y que en aquella época los jueces tenían un razonamiento tópico que no iba orientado a «aplicar la norma» sino que se dirigía a resolver el caso concreto que se estaba juzgando. Con medidas como los órdenes de prelación, se iba constreñiendo la libertad de razonamiento de los jueces y marcándoles un camino a seguir, dentro de lo que sería la evolución histórica del papel de los juzgadores.

3.3. Las compilaciones o recopilaciones de normas jurídicas

Si bien la legislación era fruto de las atribuciones de la mayoría de las asambleas parlamentarias medievales y modernas de los diversos territorios europeos, junto con la legislación propia del monarca en cada uno de estos territorios, y de otra legislación que pudiera haber, las maneras como se llevó a cabo la recopilación o recogida de estos diversos tipos de disposiciones no fue uniforme.

Dentro de este contexto europeo, si partimos de la situación hispánica, y de las atribuciones legislativas que en los diferentes territorios bajomedievales y modernos correspondían al monarca solo, o bien al monarca con la participación de sus naturales estructurados estamentalmente en asamblea parlamentaria (o, todavía, y en menor grado, a la misma costumbre), con el paso de los años podremos constatar que se había ido generando un volumen de disposiciones y de legislación importante, no siempre fácil de conocer, de consultar y, aún menos, de manejar.

Nos daremos cuenta enseguida si pensamos en los *quaderns de cort* catalanes, valencianos, aragoneses o los **ordenamientos de cortes** castellanos que recogían la legislación variada y diversa que se había elaborado en cada reunión de cortes (del mismo modo que en el Parlamento inglés se reunían las disposiciones de una determinada reunión en los *statute rolls*).

Cuanto más cuadernos de cortes, mayor complejidad para poder localizar con facilidad una disposición concreta y tener al alcance de la mano determinada legislación. Esto era así porque la legislación se iba tratando y aprobando, disposición tras disposición, mientras duraba el trámite, y quedaba por el orden que quedaba, de aprobación; acabado este trámite y el resto de actuaciones de la asamblea parlamentaria, en el acto de conclusión se promulgaba la legislación aprobada, el rey la juraba y los estamentos prestaban el consentimiento a la oferta, servicio o donativo (que era la contribución económica que con carácter extraordinario se concedía al monarca con ocasión de la celebración de la asamblea). El resultado era que la colección de disposiciones de la reunión no respondía necesariamente a ningún orden sistemático de materias, y dos disposiciones sobre la misma cuestión podían quedar muy separadas, sin ningún orden especial. Cuantas más reuniones de cortes, y más cuadernos de legislación, mayor complejidad habría para localizar unas disposiciones determinadas.

Se debe precisar que en varios territorios y épocas había, como sabemos, obras legislativas¹¹ de alcance general denominadas *codex* o **código** que coexistían con otras obras también legislativas que tenían otras denominaciones, y de estas había también de ámbito municipal.

Ejemplos de obras llamadas *codex* o **código**:

- el *Código Gregoriano*,
- el *Código Hermogeniano*,
- el *Código Teodosiano*,
- el *Código de Eurico*,
- el *Codex Revisus*, o
- el *Código de Justiniano*.

Ejemplos de obras generales con otras denominaciones:

- *El Breviario de Alarico II* o *Lex Romana Visigothorum*,
- la *Lex Romana Burgundionum*,
- el *Liber iudiciorum*,
- el *Fuero Real*,
- el *Espéculo*,
- las *Partidas*,

⁽¹¹⁾ Encontraréis más información sobre las obras legislativas en el apartado «Los juristas como fuente del derecho, apogeo y decadencia» del módulo «Lección I: El derecho del mundo mediterráneo. De la antigüedad a Europa», en los apartados «El derecho feudal de la Lombardía», «El método escolástico boloñés» y «La dimensión política, social y práctica de la recepción» del módulo «Lección II: La Europa medieval (s. IX-XV)».

- el *Vidal Mayor*,
- los *Furs de Valencia*,
- los *Fueros de Aragón*,
- los *Usatges de Barcelona*,
- las *Ordenações Afonsinas*,
- las *Ordenações Manuelinas*,
- las *Ordenações Filipinas*, o
- las *Constitucions i altres drets de Catalunya*.

Ejemplos de obras municipales con otras denominaciones:

- en Lérida, las *Consuetudines Ilerdenses*;
- en Tortosa, las *Costums de Tortosa*;
- en Gerona, las *Consuetudines Dioecesis Gerundensis*, o,
- en Portugal, el *Regimento dos oficiais das cidades, vilas e lugares destes reinos*.

Esta diferencia formal en la denominación no se corresponde con una diferencia de tipología. Independientemente de su designación, son obras de un mismo tipo.

Tanto unas obras como otras, conceptual e independientemente de las normas concretas que recogieran (del rey, del rey con los estamentos en asamblea estamental, de ámbito municipal, de origen consuetudinario...), no eran sino de un mismo tipo: eran compilaciones o recopilaciones de disposiciones de derecho, es decir, **recopilaciones**.

De todas estas obras, ahora, las que más nos interesan y llegaron a ser más conocidas son las que recogían el **derecho general de un territorio**. Como ya hemos apuntado y veremos, no será hasta la entrada en escena del pensamiento ilustrado, con el triunfo de la Revolución Francesa, cuando se podrá llevar a la práctica el nuevo concepto de código¹² –tal como lo conocemos todavía hoy– como la forma básica de la nueva legislación de las diversas ramas del ordenamiento (civil, penal y mercantil) prevista en los textos constitucionales de los estados liberales de derecho del siglo XIX.

Antes hemos tratado la profesionalización de los oficiales y cargos de numerosas instituciones, así como el crecimiento del número de juristas, aspectos favorecidos por la generalización de los estudios jurídicos desde la edad media. Todos los estudiantes que habían estudiado los textos del *ius commune* y, en concreto, de la compilación justiniana, tenían como referente para estructurar mentalmente las categorías jurídicas la **tabla de títulos del Código de Justiniano**.

El elemento técnico de las compilaciones, lo que las caracterizaba, era, pues, que se trataba de una recopilación; una recopilación que agrupaba los materiales legislativos seleccionados en una única obra, y, prácticamente siempre, en un único volumen.

Recopilaciones

Recopilaciones era el nombre con que se referían a esas obras, y también se usaba, entrada la edad moderna, el de **recopilaciones**. Etimológicamente, el término *compilar* (y *recopilar*) hace referencia al hecho de ‘agrupar’, en este caso, leyes y disposiciones –dispersas– en una misma obra.

⁽¹²⁾Más información en el apartado «La codificación» del módulo «Lección IV: El derecho contemporáneo».

Tabla de títulos del Código de Justiniano

Como era la parrilla conceptual a partir de la cual se organizaba su visión (jurídica) del mundo y se estructuraba el pensamiento de las profesiones jurídicas en diversos territorios, se usó esta tabla de conceptos (**la tabla de títulos del Código de Justiniano**, adaptada a cada caso concreto), para organizar la legislación propia y los contenidos de las compilaciones de derecho general territorial (por ejemplo, en el Principado de Cataluña, o en el Reino de Valencia).

Desde este punto de vista concreto, no representaba ninguna novedad respecto de las obras de los periodos anteriores. Otra cuestión fue el salto cualitativo y técnico que supuso el conocimiento derivado del estudio del *ius commune*, por ejemplo, por lo que respectaba a los aspectos internos de los materiales recopilados (como por ejemplo en la redacción de las normas) o a los aspectos propios de las recopilaciones (por ejemplo, la organización interna para clasificar las disposiciones seleccionadas).

El progreso que supusieron los estudios jurídicos permitió, pues, mejorar la ejecución de los criterios con que se elaboraban las recopilaciones y cómo se estructuraba su contenido.

En general, pues, se tendió hacia una **ordenación sistemática** de los materiales legales seleccionados, de acuerdo con un determinado **orden de materias** y, dentro de cada materia, por **orden cronológico**. Si la ordenación por materias permitía agrupar las normas por el tema tratado, el orden cronológico permitía recorrer la legislación vigente compilada de la más antigua a la más nueva. De este modo, y con los índices correspondientes, se facilitaba bastante la búsqueda, la localización y la consulta de las disposiciones.

Los problemas que planteaban las recopilaciones estaban vinculados con determinados aspectos directamente relacionados con sus orígenes, por un lado, y, por el otro, con aspectos de carácter técnico. Cuestiones como por ejemplo si la iniciativa para realizar una recopilación era del rey (como pasó en el Reino de Castilla) o de los estamentos (como pasó en el Principado de Cataluña), o qué tipo de normas se querían incluir en la compilación, ilustrarían los primeros supuestos; un caso de los segundos sería si la recopilación tenía carácter exclusivo o no.

Una cuestión técnica como esta del carácter exclusivo no era irrelevante. Cuando una recopilación era promulgada con carácter exclusivo, únicamente tenían valor legal las normas recogidas en la recopilación tal como habían sido recopiladas. Es decir, solo continuarían vigentes las disposiciones que habían sido incluidas en la recopilación, y tenía que ser, precisamente, con la misma forma como habían sido recopiladas (como sabemos que pasó, por ejemplo, con las *Decretales* de Gregorio IX o *Liber Extra*). Esto quiere decir que, si durante el proceso de elaboración de la recopilación con carácter exclusivo, como sucedía a menudo, en el momento de recopilar se había tenido que hacer alguna modificación (corrección, aclaración, enmienda, re-redacción, etc.), en algunos de los textos escogidos, valdría la modificación hecha, valdría el texto modificado, aunque el texto original anterior, a partir de entonces, ya no coincidiera con la redacción reelaborada de la norma, y, por tanto, ya no tuviera validez. Este fue el caso, por ejemplo, de la *Nueva recopilación* castellana de 1567, promulgada con carácter exclusivo.

La elaboración de recopilaciones facilitaba el conocimiento del derecho y el manejo de las disposiciones legales; evitaba tener que recurrir necesariamente a los cuadernos de cortes. Las compilaciones catalanas conocidas como *Constitucions i altres drets de Catalunya* de los siglos XV, XVI (1588-89) y XVIII (1704) nunca tuvieron carácter exclusivo. En estos casos, las normas eran recopiladas tal y como habían sido promulgadas, no se alteraba su vigencia y se podían invocar indistintamente de cualquier fuente o recopilación.

Por lo que respecta al caso francés, en que la autoridad y el poder del monarca habían tenido un desarrollo más amplio y con menos participación de los estamentos, a partir del siglo XVI se detecta una preocupación para continuar buscando una unidad del derecho de los territorios franceses, a diferencia de los casos peninsulares, o del inglés, con otro sentido, para buscar una unificación del derecho.

«Unificar el derecho suponía de entrada un trabajo importante de inventariar y de censar las múltiples fuentes que lentamente habían dado lugar a un sistema jurídico cuya diversidad hacía difícil su conocimiento y cuyo pluralismo paralizaba la eficacia. La monarquía del Antiguo Régimen nunca llegó a establecer, en forma de código, una compilación completa y fiable de sus ordenanzas y otros actos de poder soberano. A pesar de los intentos repetidos a lo largo de los dos últimos siglos medievales, deberá esperarse al siglo del Renacimiento para que Fontanon publique en 1580 una primera recopilación de las ordenanzas de los reyes de Francia desde 1108.»

Albert Rigaudière (2004). «Un rêve royal français: l'unification du droit». *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres* (pág. 1559).

De hecho, la recopilación de Fontanon en 1580, y la que la completaba de 1620 de Néron y Girard, no pasaron de ser recopilaciones privadas dirigidas a la práctica, y, por tanto, incompletas. Una tentativa a escala estatal de Enrique III de recoger sus leyes principales y las de sus predecesores, publicada en 1603 y realizada por Brisson, nunca se llegó a aplicar.

Se aspiraba a un derecho general, que trascendiera la mera recopilación de leyes y que evidenciara la fortaleza de la monarquía, la unidad territorial, el empuje legislativo de una de las potencias europeas de la época. Estas aspiraciones, ante la falta de unificación real del territorio y con una monarquía fortalecida y absoluta que había difundido sus leyes e ideas a través de la lengua francesa, logró, en la segunda mitad del siglo XVII –como hitos de un proceso de codificación que no se culminará–, redactar cuatro *ordonnances* concretas, impulsadas por Luis XIV y por Colbert. Dos sobre procedimiento, una civil (1667) y una criminal (1670). Las otras dos, sobre materia comercial (1673) y de comercio marítimo (1681).

En este contexto de no acabar de lograr la unificación, la monarquía difundía las ideas del absolutismo a través de textos redactados en francés –lengua de la monarquía– y no en latín. Dentro de una tendencia iniciada desde el siglo XV con Luis XI (rey de 1461 a 1483) en que se tenían que redactar todas las costumbres en francés, la monarquía absoluta lo hacía tanto mediante textos legales, tal como disponía, entre otras, la ordenanza de Villers-Cotterets de 1539, como con textos doctrinales (obras de Bodin, Lebreton o Loyseau). Otro caso de paso del latín a la lengua propia: a comienzos del siglo XV, en las cortes de Barcelona de 1412-1413, se pidió y decidió que se tradujeran al catalán las constituciones



Portada del volumen I de las *Constitucions i altres drets de Catalunya* de 1704

Fuente: <http://www.apsmc.cat/obres/constitucions-y-altres-drets-de-catalunya-i-i-ii/>



Portada de la *Ordonnance* sobre procedimiento criminal de 1670

Fuente: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9602565z.r=langFR>

y otras normas de derecho general de Cataluña (al mismo tiempo que se recopilaban), para que pudieran ser comprendidas por todo el mundo.

Fue con Luis XIV, por una decisión de 1700, cuando se empezó la tarea de buscar e inventariar las ordenanzas registradas en los diversos tribunales, trabajo pesado que se llevó a la práctica con lentitud. Se publicaron los catorce primeros volúmenes, llamados *Ordonnances du Louvre*, entre 1723 y 1790, y el resultado presentó bastantes carencias; no pueden tener la consideración de ser *corpus* completo de la legislación real del monarca absoluto antes de la revolución. Un camino parecido se había seguido desde el proceso de redacción y unificación de las costumbres, iniciado por la ordenanza de Montils-lès-Tours en 1454 y, después de varias tentativas y textos poco logrados, se tuvo que esperar al año 1724, en que Bourdot de Richebourg publicó oficiosamente el *Nouveau Coutumier Général*, que fue el más exitoso de todos, dadas las circunstancias.

De hecho, en Francia, se puede decir que la tarea de unificación del derecho en el Antiguo Régimen nunca llegó a tener éxito, porque la monarquía nunca llegó a controlar efectivamente el contenido de las diversas fuentes del derecho ni de donde provenían, nunca llegó a controlar completamente el conjunto de normas que regían el territorio.

La tarea realizada en las *ordonnances* concretas sobre cuestiones específicas (por ejemplo, las de materia comercial de 1673 y de comercio marítimo de 1681), dada su calidad técnica, acabó sirviendo, al fin y al cabo, de base para los trabajos preparatorios de la codificación (de comienzos del siglo XIX en Francia por parte de Napoleón). En tiempos de Luis XV, en el siglo XVIII, el canciller d'Aguesseau redactó y promulgó tres ordenanzas específicas más, relativas a temas clave de los derechos privado, patrimonial y de familia. Una en relación con las donaciones en 1731, una segunda sobre testamentos en 1735 y una tercera sobre sustituciones en 1747.

En la España del siglo XIX¹³, siquiera por la subsistencia limitada de ordenamientos jurídicos propios de los antiguos territorios (Aragón, Cataluña, Navarra, etc.), la manera de abordar el proceso codificador y la solución misma que se adoptará durante la elaboración del Código civil de 1889 se verán condicionadas por ello.

⁽¹³⁾Ved el módulo «Lección IV: El derecho contemporáneo».

4. Los juristas y la construcción del estado

4.1. La generalización de las profesiones jurídicas

Desde la difusión de los estudios del *ius commune* se empezó a tomar conciencia de la importancia que tenían las personas formadas y preparadas técnica y profesionalmente en los estudios generales de derecho¹⁴.

Los estudiantes que habían completado sus estudios eran **doctores en derecho**. Si habían estudiado solo derecho civil, eran **doctores en derecho civil**. Si habían estudiado derecho canónico, eran **doctores en derecho canónico**. Si habían estudiado los dos, cosa bastante habitual a partir de la escuela de los comentaristas, entonces eran **doctores en ambos derechos** (o *utrumque iuris doctores*, como se les llamaba en latín).

Ese proceso gradual de incorporación progresiva de juristas formados en cargos técnicos de la administración del territorio o de la institución de donde procedían se desarrolló al mismo tiempo que iban tomando cuerpo las monarquías medievales primero, y, después, los estados modernos. Con los cambios que se iban produciendo y la aparición de nuevas necesidades, las instituciones tenían que adaptarse a las nuevas circunstancias, por ejemplo el crecimiento o el incremento de los dominios territoriales así como de la población, con la consiguiente necesidad de ejercer el control correspondiente (por ejemplo, manteniendo el orden público o controlando las exacciones fiscales).

4.2. La especialización en los cargos y oficios de las instituciones públicas

Hemos ido viendo en los apartados precedentes que la mejora en la preparación técnica y en la profesionalización de los estudiantes formados en los estudios de derecho revertían en un cuerpo de oficiales cada vez más preparados y en una tecnificación institucional que, a su vez, reclamaba cada vez más personas mejor preparadas.

Dejando aparte este aspecto profesional vinculado a los cargos de la administración, y también el papel tan relevante que tuvieron estos cargos en la consolidación del poder absoluto del monarca, debe tenerse presente que la tendencia será, con la caída del Antiguo Régimen y la formación del estado nacional, sobre las bases jurídicas del estado liberal, evolucionar hacia un proceso

⁽¹⁴⁾Ved los apartados «La formación de la ciencia jurídica europea» y «Pluralidad de ordenamientos jurídicos (s. XII-XIV)» del módulo «Lección II: La Europa medieval (s. IX-XV)».

⁽¹⁵⁾Ved el apartado «El gobierno representativo y la ley» del módulo «Lección IV: El derecho contemporáneo».

equivalente (y desde entonces constitucional) de burocratización y funcionalización, en el cual los orígenes de la burocracia contemporánea arrancarán de la Revolución Francesa¹⁵.

Al lado de los elementos apuntados, seguía habiendo otras salidas profesionales para los juristas. Había juristas con una gran capacidad de trabajo que desarrollaron, más allá de sus actividades profesionales, tareas de creación intelectual, de estudio y sistematización de la legislación del territorio respectivo, como un paso más en la evolución de este proceso de afianzamiento del conocimiento jurídico y sistematizador de la ciencia jurídica.

4.3. La contribución de los juristas en la creación de la ciencia del derecho

Ya hemos visto que el renacimiento de los estudios jurídicos en Bolonia fue capital por lo que se refería a la construcción y al desarrollo de una materia de estudio nueva y autónoma, **el derecho**. Y lo fue hasta el punto de que aquellos primeros juristas, los glosadores, pueden ser considerados los fundadores de la ciencia jurídica de la Europa moderna.

Dentro de la **ciencia jurídica europea** hay elementos procedentes de otras tradiciones, no siempre tan claramente identificables como los romanos. Esto es así porque la cultura romana actuó de filtro asimilador del legado cultural de la antigüedad, del mismo modo que en su momento lo hizo con la cultura griega. Habría, así, una línea que enlazaría con los juristas clásicos, que podríamos considerar los padres espirituales de nuestra sociedad, y la Grecia clásica.

Conviene aclarar que en este camino (denominado por algunos autores como el de la **juridificación de Europa**), junto con los juristas hubo otras intervenciones (por ejemplo, de teólogos, de humanistas y de naturalistas) que seguían las huellas del derecho romano, el cual, desde la Alta Edad Media, se había convertido en modelo de referencia para toda la cultura jurídica europea de alto nivel (del mismo modo que la griega lo era en el ámbito de la filosofía).

Podemos destacar la idea de que el derecho es la base de una sociedad regulada, la importancia del proceso judicial y papel social del derecho y del ordenamiento jurídico como tres aportaciones relevantes de griegos y romanos, coincidentes con la tradición judeocristiana.

Fue sobre estas bases comunes compartidas por la tradición jurídica que la ciencia jurídica, en especial a partir del redescubrimiento de los textos justinianos y del estudio de los textos canónicos y gracias al impulso de las escuelas de Bolonia y de Orleans, fue evolucionando y se fue conformando en los diversos territorios europeos. Todo este conjunto de elementos de diversa procedencia y grado acabaron siendo incorporados al saber jurídico del mo-

mento gracias a la tarea de los juristas. Debe decirse que, además de contar con las aportaciones propias de cada una de las tradiciones mencionadas, se disponía también de las que podían provenir de otras culturas o realidades, con las que había habido algún tipo de contacto. Este era el caso, por ejemplo, de los pueblos germánicos, y, especialmente, de la Iglesia católica.

Fue en este proceso cuando se consolidó el interés de los juristas por los **derechos propios** de sus respectivos territorios. Se entró en una fase en la que, gracias al trabajo llevado a cabo por los juristas precedentes (entre otros, la identificación de conceptos, axiomas, dogmática...), los juristas del momento pudieron dedicarse a un nuevo nivel de estudio: pensar cómo se podía unificar el derecho desde el punto de vista científico, lo que les permitió plantearse la construcción de sistemas jurídicos teóricos.

a) Portada de la obra *De pactis nuptialibus* t. I del jurisconsulto de Olot Joan Pere Fontanella, publicada en Ginebra. b) Portada de la obra del jurisconsulto Miquel de Cortiada reeditada en Venecia en 1727. c) Portada de la obra *De pactis nuptialibus* t. II del jurisconsulto de Olot Joan Pere Fontanella publicada en Lyon



Fuente: a) http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10494833_00007.html. b) http://www.europeana.eu/portal/record/9200110/bibliographicresource_1000126583742.html. c) <http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5326830433;view=1up;seq=7>

La lengua de cultura era el latín, y en los centros de enseñanza del derecho de los diversos territorios se fue trabajando de forma que se integraban en ellos todos estos elementos. Las obras jurídicas de autores de diferentes lugares eran accesibles por la lengua empleada y podían ser útiles (hasta cierto punto) para los autores de otros lugares; esto se confirma no solo por las citas que unos hacían de las obras de los otros que se hallan en las obras publicadas, sino también por los inventarios conservados de las obras que tenían en sus bibliotecas profesionales. A todo ello contribuía también la existencia de una estructura comercial específica sobre los libros de especialidad, que tenían su propio mercado. En este contexto, en la edad moderna había muchas obras jurídicas de autores originarios de diferentes territorios que habían sido publi-

cadras por imprentas especializadas, localizadas en áreas geográficas concretas de Francia (por ejemplo, en Lyon), de la actual Suiza (por ejemplo, Ginebra) o de Italia (por ejemplo, Venecia).

La mejor preparación y formación de los estudiantes supondría la extensión del número de licenciados, que podrían desarrollar sus profesiones jurídicas como juristas competentes.

Y fueron algunos de estos juristas los que contribuyeron al progreso teórico de la ciencia del derecho, a la formación –y, sobre todo, a la consolidación– del estado, desde varios puntos de vista, ya sea –unos cuantos– como teóricos, ya sea –otros muchos– como simples (pero absolutamente necesarios) oficiales y cargos encargados de alguna de sus instancias administrativas.

Todo este proceso de evolución abarca distintos momentos temporales y varias aproximaciones o actitudes intelectuales, que se van sucediendo en el tiempo y van aprovechando de estadios anteriores, para construir nuevos avances en este camino de la sistematización del derecho y la ciencia jurídica.

4.4. Humanismo jurídico, las bases de una nueva concepción del derecho (siglos XV-XVIII)

Por lo que nos interesa ahora, el primer escalón que hemos visto sería el del redescubrimiento de los textos jurídicos en Bolonia y el estudio de los textos del derecho romano justiniano, con la construcción de un método nuevo, **la glosa**. Una vez agotado de manera natural, se vería superado por el método del **comentario**, y los dos constituirían el legado del *ius commune* y del bloque de autores del *mos italicus*¹⁶. Con la llegada del Renacimiento y la reacción que se produce contra el mundo medieval, por el cual se sentía aversión, el **humanismo** conllevará una manera nueva de concebir el mundo, con el hombre en el centro y reubicando a la divinidad, y, por tanto, también una manera nueva de mirar el derecho.

⁽¹⁶⁾Ved los apartados «Pluralidad de ordenamientos jurídicos (s. XII-XIV)» y «La recepción del *ius commune*» del módulo «Lección II: La Europa medieval (s. IX-XV)».

La nueva manera de mirar el derecho es la de los autores del *mos gallicus*, los cuales incorporarán a su bagaje heredado, principalmente, crítica, contexto, visión histórica y sistematización, además de otros elementos. Como veremos, esta corriente será un estadio más de evolución y acabará siendo superada por la escuela del derecho natural, el **iusnaturalismo**¹⁷.

⁽¹⁷⁾Ved el apartado «Iusnaturalismo racionalista» del módulo «Lección IV: El derecho contemporáneo».

Si el estilo y el método de trabajo iniciado por los glosadores en Italia y continuado por los comentaristas en todo el occidente medieval recibieron el nombre de *mos italicus*, el de los juristas de la tradición del humanismo renacen-

tista será conocido con el nombre de *mos gallicus*, para contraponerse y distinguirse. Y esta escuela del *mos gallicus*, nacida en el siglo XV, tendrá plena continuidad en los siglos XVI y XVII y perdurará hasta el XVIII.

Como hemos visto en el módulo anterior, los comentaristas se apartaban de la literalidad del texto, porque ya no se sentían vinculados a la letra de la ley como los glosadores, y elaboraban construcciones más interpretativas y, por tanto, más creativas que sus antecesores. Eran también una escuela con un planteamiento que se podría considerar más práctico y con una proyección más aplicada, preocupada por poder resolver casos singulares y no solo por construir grandes teorizaciones. No obstante, para ellos el derecho romano justiniano continuaba siendo considerado un bloque monolítico y era tratado indistintamente en su integridad. Dicho con otras palabras, trataban igual y con el mismo valor jurídico un fragmento atribuido al jurista Escévola, que vivió en el siglo II a. C., que una constitución imperial del siglo IV, o una novela de Justiniano, del siglo VI. Para los comentaristas la compilación justiniana encarnaba la *ratio scripta* (la razón escrita) y no manifestaban una posición crítica ante los textos legales, si bien es cierto que la actitud de los glosadores fue diferente de los comentaristas, los cuales, a partir de la comprensión total de los textos y aplicando un método lógico y dialéctico, elaboraban las soluciones a los casos planteados. Los comentaristas aplicaban el criterio de autoridad, y la autoridad era, sobre todo, el mismo derecho romano, como si su vigencia y vigor fueran intemporales. Visto desde el siglo XVI, por ejemplo, el *mos italicus* sería la manera «tradicional» o medieval de aproximarse al derecho romano.

En el siglo XVI la escuela del *mos italicus* ya mostraba síntomas de agotamiento y de repetición; los autores a menudo entraban en bucles de citas y más citas. Esta práctica, en el fondo, lo que hacía era esconder la ausencia de originalidad del autor de la obra, que no aportaba doctrina ni soluciones nuevas y ni siquiera reiteraba la doctrina de autores precedentes. Se había derivado en una auténtica hipertrofia de citas, con remisiones a textos romanos y a autores anteriores consagrados. Por otro lado, esta cantidad ingente de citas y de remisiones hacía que los textos fueran difíciles de leer y de comprender. La corriente del *mos gallicus* representó una evolución y una superación de este modo de trabajar.

4.4.1. *Mos gallicus*

En los siglos XV y XVI tuvo lugar en Europa el movimiento cultural del Renacimiento de la cultura clásica grecorromana. Este movimiento aportaba una visión humanista de la sociedad en todos sus ámbitos; una visión alejada de las tendencias medievales en filosofía, arte y en todas las manifestaciones culturales de la sociedad. Esta corriente humanista no incidió directamente o de manera sustancial en el derecho, pero de una manera indirecta, como veremos, sí que lo acabó afectando.

Ya hemos visto que todo el edificio del *ius commune*, que sobre todo era una construcción de los juristas, reposaba en la obra de Justiniano y en los textos canónicos medievales. Los humanistas, en el ámbito del derecho, son conocidos como la **escuela del *mos gallicus***, porque los máximos representantes de esta corriente eran franceses, de lo que sería la antigua provincia imperial, la Galia romana.

Los autores del *mos gallicus*, los humanistas, centraron su atención en los textos de la compilación de Justiniano, pero lo hicieron desde una perspectiva muy diferente a como se había hecho desde entonces. Y lo hicieron dándole una dimensión histórica, con el fin de restituir el texto original de la compilación; una finalidad que no había interesado para nada a los juristas medievales ni del *mos italicus* porque su objetivo, como hemos visto, era otro. Para lograr su finalidad, los humanistas se ayudaron de la crítica filológica y estudiaron los textos relacionándolos con su contexto (el de cada texto), o sea, en relación con la cultura y las instituciones de la antigüedad, y también realizaron ediciones críticas de obras medievales.

El alcance final de esta crítica del *mos gallicus* sobre el *mos italicus* es notable porque va mucho más allá de lo que era un simple cambio de perspectiva. Para los juristas medievales, la compilación de Justiniano era un todo íntegro y monolítico. Para los humanistas, en cambio, era una compilación de textos legales de la cual pretendían singularizar cada pieza concreta –no cada libro de la compilación, sino cada ley y cada autor– para, en su caso, restituir el texto, y conectarla con su contexto originario, histórico.

Con el humanismo jurídico, el derecho romano devino objeto de investigación histórica.

Si toda la doctrina del *mos italicus* y del *ius commune* se basaba en los textos que habían sido fijados en Bolonia y ahora, con el humanismo, estos textos fundacionales eran cuestionados (porque se descubrían en ellos corrupciones, errores, falsificaciones, interpolaciones...) y se les restituía su originalidad genuina e histórica, está claro que ello ponía en riesgo de manera inevitable la misma doctrina que estos textos habían generado hasta entonces y que había ido creciendo y desarrollándose como una gran bola de nieve.

De hecho, las investigaciones humanistas –históricas y filológicas– sobre la compilación de Justiniano negaban parcialmente la validez de la propia compilación: por un lado, porque se negaba la reordenación de los volúmenes que de la misma se había hecho en Bolonia –provocada, como recordaréis, por la llegada desigual de los libros legales–; y, por el otro, porque se consideraba que

Escuela del *mos gallicus*

Se considera que el fundador de la escuela fue el jurista italiano **Andreas Alciatus** (1492-1550); poco seguido en Italia, lo fue mucho en Francia, a raíz de la escuela que fundó en Bourges, ciudad situada en el centro del reino.

Autores humanistas

Autores relevantes de esta corriente, de origen italiano o francés, fueron: Lorenzo Valla (1407-1457), Alberico Gentili (1452-1608), Guillaume Budé (1467-1540), Jacques Cujas (1522-1590), François Hotman (1524-1590) o Denis Godefroy (1549-1622). La escuela se expandió a otros territorios, como el alemán, el suizo y el holandés.

la compilación justiniana era, por ella misma, una alteración del derecho romano primigenio (que ellos querían restituir, críticamente, al estadio clásico antes de la intervención de Justiniano).

Pero el humanismo jurídico, a pesar de la crítica que les hacía, y su posición contraria al mundo medieval, no provocó una ruptura total o una escisión completa con el *ius commune*. De hecho, los humanistas del *mos gallicus* adoptaron una actitud diferente: trataron con mucho más rigor histórico-filológico los textos jurídicos, se alejaron de los criterios de la escolástica medieval y decantaron definitivamente su interés doctrinal hacia las instituciones propias de su época.

Esta depuración de la base jurídica romana que abordó el *mos gallicus* provocó que se incrementara el divorcio entre el derecho romano (cada vez más alejado de la compilación justiniana) y la doctrina del *ius commune*. Si se puede decir que la obra de glosadores y comentaristas había sido como la sombra de los textos legales –pegada a los textos legales–, ahora los dos elementos (obra y textos legales) circulaban ya de manera casi independiente.

Esta tendencia que relatamos, sin embargo, no era sostenible, porque la crítica a la compilación justiniana, de hecho, minaba las bases de la propia doctrina del *ius commune*. Así, la tendencia que impulsaba el *mos gallicus*, que formalmente formaba parte de la vasta cultura jurídica del *ius commune*, conducía poco a poco hacia escenarios diferentes: hacia posiciones políticas que legitimaban más las aspiraciones realistas, o hacia posiciones más laicas (en detrimento del elemento canónico que impregnaba el *ius commune*), y también, como consecuencia de lo que acabamos de decir, hacia una reivindicación de la potestad legislativa (que creaba derecho nuevo) en detrimento de un derecho de juristas, porque esto es lo que era, en esencia, el *ius commune*, un derecho de juristas que había sido el hegemónico hasta entonces.

A estas posiciones, como se ha dicho, en la segunda mitad del siglo XVII y durante el XVIII, se llegaba «desde dentro» del *ius commune*, como una derivación moderna que convivía con la antigua práctica ortodoxa de raíz medieval y en crisis de lo que representaba entonces el *mos italicus*.

La nueva corriente diferenciaba cada vez más claramente *ius commune* (como equivalente a la doctrina elaborada por los juristas) y **derecho romano** (que ya no era exactamente derecho romano justiniano). Esta nueva corriente, en la cual podían participar también juristas bartolistas «moderados», recibió el nombre de *usus modernus pandectarum* (*Pandectas* era el nombre griego del *Digesto*). Del mismo modo que lo hizo la escuela del *mos gallicus*, incidieron en el desarrollo del *ius commune* de estos siglos XVII y XVIII. Entre los dos extremos opuestos de cada escuela, había un amplio espacio de aproximación y de colaboración de unos con otros.

Bibliografía

Anderson, P. (1987). *El estado absolutista* (8.ª ed.). Madrid: Siglo XXI.

Bravo Lira, B. (1981). «Oficio y oficina, dos etapas en la historia del estado indiano». *Revista Chilena de Historia del Derecho* (pág. 8, págs. 73-92).

Caenegem, R. C. van (1995). *An historical introduction to Western constitutional law*. Cambridge: CUP.

Caenegem, R. C. van (2003). *I sistemi giuridici europei*. Società Editrice Il Mulino.

Calasso, F. (1954). *Medioevo del diritto. 1. Le fonti*. Milán: Giuffrè.

Cannata, C. A. (1996). *Historia de la ciencia jurídica europea*. Madrid: Tecnos.

Canning, J. (1996). *A History of Medieval Political Thought 300-1450*. Londres / Nueva York: Routledge.

Cavanna, A. (1982-2005). *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico* (2 vols.). Milán: Giuffrè.

Clavero, B. (1992). *Institución histórica del derecho*. Madrid: Marcial Pons.

Clavero, B. (2005). *Historia del derecho: Derecho común*. Salamanca: Ediciones de la Universidad («Manuales universitarios», 53).

Domínguez Ortiz, A. (1985). «La venta de cargos y oficios en Castilla y sus consecuencias económicas y sociales». En: *Instituciones y sociedad en la España de los Austrias* (págs. 137-184). Barcelona: Ariel.

Domínguez Ortiz, A. *Las clases privilegiadas* (reedición).

Escudero López, J. A. (2008). *Curs d'història del dret. Fonts i institucions politicoadministratives*. Alicante: Publicacions de la Universitat d'Alacant.

Escudero López, J. A. (2008). «La nobleza y los altos cargos de la administración en la España del Antiguo régimen». En: L. Soberanes Fernández; R. M.ª Martínez de Codes (coords.). *Homenaje a Alberto de la Hera* (págs. 321-337). México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas («Serie Doctrina jurídica», 430).

Fédou, R. (1977). *El estado en la edad media*. Madrid: Edaf («Edaf Universitaria», 1).

Ferro, V. (1987). *El Dret Públic Català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta*. Vic: Eumo («Referències», 1).

Figgis, J. N. (1960). *Political Thought from Gerson to Grotius 1414-1625. Seven Studies by...* Nueva York: Harper Brothers.

Genêt, J. P. (2011). «État, État moderne, féodalisme d'état: quelques éclaircissements». En: *Europa e Italia. Studi in onore di Giorgio Chittolini / Europe and Italy. Studies in honour of Giorgio Chittolini* (págs. 195-205). Florencia: Firenze University Press.

Genêt, J. P. (1997). «La genèse de l'État moderne». *Actes de la recherche en sciences sociales* (núm. 118, págs. 3-18).

Gloël, M. (2014). «Las monarquías compuestas en la época moderna. Concepto y ejemplos / The Early Modern composite monarchies: Concept and examples». *Universum* (v. 2, núm. 29, págs. 83-97). Talca: Universidad de Talca.

González Casanova, J. A. (1982). *Teoría del Estado y Derecho Constitucional* (2.ª ed.). Barcelona: Vicens-Vives.

Grossi, P. (1997). «Un derecho sin estado. La noción de autonomía como fundamento de la constitución jurídica medieval». *Anuario Mexicano de Historia del Derecho* (núm. 9, págs. 167-178).

Guzmán Brito, A. (1978). «Mos italicus y mos gallicus». *Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso* (núm. 2, págs. 11-40).

Hespanha, A. M. (1982). *Historia das instituições. Épocas medieval e moderna*. Coimbra: Livraria Almedina.

Hespanha, A. M. (1998). *Cultura jurídica europea. Síntesis de un milenio*. Madrid: Tecnos.

Hilaire, J. (1995). *Histoire des institutions publiques et des faits sociaux (XIe-XIXe siècles)* (6.^a ed.). París: Dalloz.

Hintze, O. (1968). *Historia de las formas políticas*. Madrid: Revista de Occidente.

Hintze, O. (1981). «La formación jurídica de los estados». *Revista de Administración Pública* (núm. 46, págs. 24-36). México.

Ibáñez Real, M. A. (1992). «La Revolución francesa y los orígenes de la burocracia moderna». *Iztapalapa. Revista de ciencias sociales y humanidades* (núm. 27, págs. 131-154). UAM.

Iglesia Ferreirós, A. (1996). *La creación del Derecho. Una historia de la formación de un derecho estatal español. Manual I-II*. Madrid: Marcial Pons.

Keir, D. L. (1948). *The Constitutional History of Modern Britain, 1485-1937* (3.^a ed.). Londres: A. & Ch. Black.

Le Roy Ladurie, E. (2000). *L'Etat royal*. Hachette Pluriel.

Maravall, J. A. (1972). *Estado moderno y mentalidad social (siglos XV al XVIII)* (2 vols.). Madrid: Revista de Occidente. [Reed. Madrid: Alianza, 1986].

Margadant, G. F. (1986). *La segunda vida del derecho romano*. México: M. A. Porrúa.

Martínez Ruíz, E. (dir.) (2007). *Diccionario de historia moderna de España. II. La administración*. Madrid: Istmo («Fundamentos», 229).

Molas i Ribalta, P. y otros (1993). *Manual de Historia Moderna*. Barcelona: Ariel.

Reinhard, W. (1997). *Las elites del poder y la construcción del Estado*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.

Rigaudière, A. (2006). *Introduction historique a l'étude du droit et des institutions*. París: Economica.

Rigaudière, A. (2004). «Un rêve royal français: l'unification du droit». *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres* (págs. 1553-1567).

Robinson, O. F.; Fergus, T. D.; Gordon, W. M. (2000). *European Legal History. Sources and Institutions*. Londres: Butterworths.

Rodríguez Paniagua, J. M. (1988). *Historia del pensamiento jurídico*. Madrid: Universidad Complutense, Facultad de Derecho, Sección de Publicaciones.

Ruiz Miguel, A. (2002). *Una filosofía del derecho en modelos históricos. De la antigüedad a los inicios del constitucionalismo*. Madrid: Trotta.

Sabine, G. H. (2006). *Historia de la teoría política* (3.^a ed.). México: Fondo de Cultura Económica.

Sánchez Martínez, M. (1995). *El naixement de la fiscalitat d'estat a Catalunya (segles XII-XIV)*. Vic: Eumo.

Shennan, J. H. (1974). *The Origins of the Modern European State, 1450-1725*. Londres: Hutchinson.

Strayer, J. R. (1981). *Sobre los orígenes medievales del estado moderno*. Barcelona: Ariel («Ariel Quincenal», 159).

Tomás y Valiente, F. (1980). «Venta de oficios públicos en Castilla durante los siglos XVII y XVIII». En: *Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen* (págs. 151-177). Madrid: Alianza.

Wieacker, F. (1957). *Historia del derecho privado de la edad moderna*. Madrid: Aguilar. [Nueva ed.: Granada: Comares, 2000].